



Direito Empresarial

PARTE 1



**Chanceler**

Prof. Antonio Colaço Martins Filho

Reitora

Profª. Denise Ferreira Maciel

Diretor Administrativo Financeiro

Edson Ronald de Assis Filho

Diretora Executiva

Ana Cristina de Holanda Martins

Diretora Executiva

Sandra de Holanda Martins

Assessoria de Desenvolvimento Educacional – ADE

Profª. Elane Pereira

Prof. Silvio Rodrigues

Produção de Conteúdo:

Profª. Vanessa Gomes Leite

Revisão Textual

Cristiana Castro

Diagramação

Wanglêdson Costa

Sumário

Apresentação	06
Para começo de conversa	07
01 - Histórico e Conceitos	08
O Direito Empresarial: breve histórico	10
O Direito Empresarial no Brasil e o Código Civil de 2002	13
Fontes do Direito Empresarial	16
Princípios do Direito empresarial	18
O Perfil Subjetivo (individual) de Empresa	18
Empresário não equivale a preposto	19
Espécies de empresário:	23
02 - O Empresário e suas características	25
Atividade empresária:	27
Empresário Individual	30
Empresário casado:	33
Escrituração do Empresário	34
Obrigações:	35
Sistemas legais de escrituração:	35
A eficácia probatória dos livros empresariais:	35
Questões comentadas	36

Sumário

03 - Estabelecimento Empresarial	39
Estabelecimento Empresarial (art. 1142 a 1149 do CC/02)	41
Natureza jurídica do estabelecimento empresarial	44
Condições de Eficácia	46
Possibilidade de penhora do estabelecimento:	48
Exceção da sub-rogação automática:	54
Questões comentadas	58
Referências	61
Anotações	62

Apresentação



Seja bem-vindo à disciplina **Direito Empresarial**. A metodologia adotada pela **UNIFAMETRO** na modalidade a distância conta com aulas ministradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, favorecendo atividades colaborativas, aproximando professores e alunos distantes fisicamente.

Para a melhor compreensão do assunto, é importante que, além da leitura desse conteúdo, você participe das atividades e tarefas propostas no cronograma e consulte dicas e complementos sugeridos no decorrer da disciplina. Este material também está disponível para impressão ou para download em formato pdf **clcando no botão abaixo**:



educacaoonline.unifametro.edu.br

É importante ressaltar que, nessa metodologia, o seu compromisso com a aprendizagem é fundamental para que ela aconteça. Portanto, participe, lendo os textos antes de cada aula para interagir melhor nos momentos de comunicação virtual e presencial, nas discussões com os tutores, professores e colegas de curso.

**BONS
ESTUDOS!**



Para começo de conversa

A disciplina **Direito Empresarial** é dividida em **3 partes**, nas quais você encontrará o conteúdo, bem como conteúdos adicionais e sugestões de leituras. Ao longo do texto, você irá se deparar com vários ícones que irão ajudá-lo neste percurso em busca do conhecimento, tais como:



SUGESTÕES



PARA REFLETIR



OBJETIVOS



PARA LER



ATENÇÃO



EXEMPLO



SAIBA MAIS



VOCÊ SABIA



VÍDEO

Esses ícones nortearão a sua leitura, oferecendo amplas possibilidades de aprofundamento. A linguagem dialógica aqui utilizada também irá aproximá-lo das aulas ora apresentadas, levando-o à motivação e ao entendimento da disciplina. Esperamos, por meio da diagramação desse material, contribuir com sua interação plena com os conteúdos. Agora que já estamos “conectados”, mãos à obra!



01

Histórico e Conceitos





OBJETIVOS

Histórico e Conceitos

Olá turma! Como é bom estar aqui!

“Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim”.

(Charles Chaplin)



ATENÇÃO

Termos-chave

Empresa. Empresário. Capacidade.





Imagem: Freepik

O Direito Empresarial: breve histórico

Para compreender a origem do Direito Empresarial, é preciso entender o sentido de Direito que será adotado no presente estudo. Parte-se do pressuposto de que o Direito consiste em uma compartição de liberdades por meio de um conjunto de normas devidamente legitimadas (autorizadas) pelos membros da sociedade. Trata-se de um mecanismo utilizado pelo Estado para criar condições de relações e de convivência entre os indivíduos em busca de uma pacificação social. O referido ramo do Direito surgiu inicialmente para regular o comércio, sendo mais conhecido como Direito Comercial.

Haja vista a impossibilidade em que se encontram os indivíduos de saciarem todas as suas necessidades apenas com suas próprias aptidões e recursos, estes são levados a viverem em grupos e de maneira próxima para trocar os produtos excedentes de seu trabalho, o que explica a origem também da sociedade.

Nesse contexto, as relações de comércio já existiam desde a Antiguidade, mas não havia um Direito Comercial, enquanto regime jurídico sistematizado com regras e princípios próprios. Contudo, é compreensível que, nas civilizações antigas, entre as regras rudimentares do direito imperante, surgissem alguns regulamentos para delimitar as atividades econômicas (REQUIÃO, 2014, p. 32). Cite-se, como exemplo, o Código de Hammurabi.

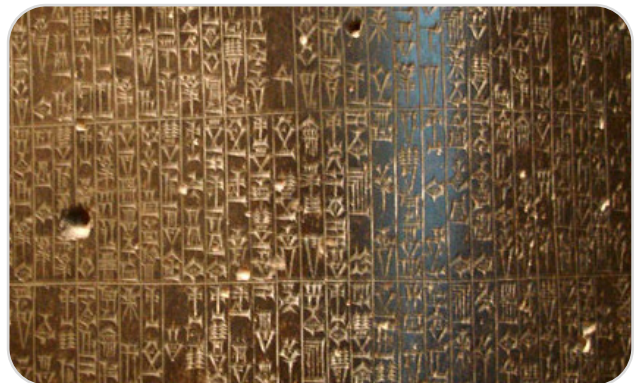


Imagem: Internet

Figura 1: Código de Hammurabi (1792-1750 ac.), Museu do Louvre, Paris.



Mesmo em Roma, não havia um Direito comercial, devido à organização estruturada precipuamente sobre a propriedade e atividades rurais, as eventuais mesmo em Roma, não havia um Direito comercial, devido à organização estruturada precipuamente sobre a propriedade e atividades rurais, as eventuais regras comerciais existentes faziam parte do direito privado¹ comum, ou seja, o direito civil. Somente na Idade Média, ainda que de maneira fragmentada, é possível identificar o Direito Comercial, oriundo da imposição do desenvolvimento do tráfico mercantil, dando início à primeira fase desse Direito.

Primeira fase: Corporações de Ofício

Na Idade Média, o poder político era descentralizado (feudalismo), o que dificultava a imposição de regras gerais para aplicar a todos, surgindo uma série de “regras comerciais locais”. Com o crescimento do comércio marítimo, irromperam as **Corporações de Ofício**, em que cada uma tinha seus usos e costumes. Diante do sucesso e do enriquecimento, conquistaram grande poder político, ao ponto de obterem autonomia para alguns centros comerciais, como as cidades italianas Veneza, Florença e Gênova. Tratava-se de uma **espécie de órgãos de classe formada pelos próprios comerciantes**, eles criavam regras de natureza jurídica voltadas a resolver os conflitos decorrentes dessa atividade comercial crescente. As regras do direito em baila foram surgindo da própria dinâmica da atividade comercial.



EXEMPLO



<https://cidademedieval.blogspot.com.br/search/label/mercados>

Diante da precariedade do direito comum (romano) para assegurar e garantir as relações comerciais, fora do formalismo que o direito romano remanescente impunha, tornou-se necessário que os comerciantes organizados criassem entre si um direito costumeiro, aplicado internamente na corporação por juízes eleitos pelas assembleias (juízo consular), ao qual deve-se a sistematização das regras do mercado. Nas corporações de ofício, tinha-se, portanto, regras de natureza comercial feitas pelos comerciantes e para os comerciantes (RAMOS, 2014, p. 4). Com efeito, o professor Alfredo Rocco (apud REQUIÃO, 2014, p. 35) explana:



Aos costumes formados e difundidos pelos mercadores, só estes estavam vinculados; os estatutos das corporações estendiam a sua autoridade até onde chegava a autoridade dos magistrados das corporações, isto é, até aos inscritos na matrícula; e, igualmente à jurisdição consular estavam sujeitos, somente os membros da corporação.

Assim, se você fosse um comerciante inscrito nas corporações de ofício, contaria com a proteção daquelas normas de natureza comercial; porém, se você não fosse, estaria sujeito à legislação comum (civil), não contando com a proteção das normas dessas corporações. Por conta disso, predominava o **caráter subjetivista e classista**, no sentido de só quem era comerciante eram aqueles filiados a uma corporação de ofício. As relações jurídicas mercantis eram definidas, portanto, pela qualidade do sujeito. Estava-se diante do corporativismo, em que, se você era filiado contava com a proteção, se não era filiado, mas praticava atos de comércio, ainda assim não contava com proteção. Cadê a igualdade? Não havia!

Acontece que, em um segundo momento, irrompem as fases das revoluções, que se espalharam mundo a fora, destacando-se a Revolução Francesa, de 1789, impulsionada pelos ideais da igualdade, liberdade e fraternidade, que influenciaram outros Estados Nacionais. A sociedade liberal, liderada pela burguesia, pregava a igualdade política, social e jurídica. Foi um período marcado por profundas transformações políticas, sociais e econômicas. As normas subjetivistas do primeiro estágio do Direito Comercial não mais se sustentavam, ao passo que se relaxava a exigência da matrícula como condição para o comerciante submeter-se à jurisdição consular, estendendo-se sua competência a comerciantes não matriculados.

Nesse contexto, surge na França, fruto do labor dos juristas de Napoleão Bonaparte uma nova teoria, a teoria dos atos de comércio, marcada pelo objetivismo.

Segunda Fase: Teoria dos Atos de comércio

O código comercial francês elaborado pelos juristas do Napoleão Bonaparte estava calcado nessa teoria, ela rompe com o subjetivismo das corporações de ofício, sendo **pautada pelo objetivismo**, excluindo o privilégio de classes. A partir disso, contariam com a proteção das normas de natureza comerciais aqueles que praticassem atos tipificados como atos de comércio.

***O Código Comercial francês de 1807
consistiu em um estatuto disciplinador dos
atos de comércio, a que estavam sujeitos
todos os cidadãos (REQUIÃO, 2014, p. 36).***

Esse modelo calcado no objetivismo da 2ª fase de formação do direito empresarial **trazia um problema considerável, qual seja: a sua incapacidade de acompanhar**



a evolução do direito comercial. O direito é uma ciência dinâmica, todos os dias surgem, fruto do espírito inventivo do homem, novas formas mercantis. Por sua vez, a teoria dos atos de comércio era **estática**, paradinha.

Começam a surgir novas formas mercantis que não estavam elencadas no **rol taxativo** do código comercial francês dos atos de comércio, inclusive após a Revolução Industrial. Por conta disso, começa a ruir o modelo da teoria dos atos de comércio. E surge, na Itália, uma nova teoria, a teoria da empresa, fruto do Código Civil italiano de 1942

Terceira Fase: Teoria da empresa:

Nessa teoria de origem italiana, o direito empresarial passa a incidir em qualquer pessoa ou grupo que pratique a atividade empresária (forma específica de exercer uma atividade econômica). Não levava em consideração o subjetivismo das corporações de ofício, nem limitava a proteção apenas a um rol taxativo de quem praticasse atos de comércio. Contarão com a proteção das normas de natureza empresarial, aqueles que pratiquem a ATIVIDADE EMPRESÁRIA (atividade econômica habitual e organizada com a finalidade de fazer circular bens ou serviços), isto é, aqueles que exercem a empresa. Assim, empresa não é um lugar, mas a atividade empresária propriamente dita.

O Direito Empresarial no Brasil e o Código Civil de 2002

A teoria dos atos de comércio extrapolou as fronteiras da França e irradiou-se pelo mundo, inclusive chegando ao Brasil.

Registre-se que, durante o Brasil-colônia, as relações jurídicas pautavam-se pela legislação de Portugal (Ordenações Filipinas; Manuelinas e Afonsinas). A situação muda após a vinda de D. João VI ao Brasil, com a abertura dos portos às nações amigas, mediante a Lei de Abertura dos Portos de 1808. Dentre os importantes atos de monarquia recém-instalada, cabe mencionar o alvará de 12 de outubro de 1808, que criou o Banco do Brasil, com programa de emissão de bilhetes pagáveis ao portador, operações de descontos, comissões, depósitos pecuniários, dentre outros (REQUIÃO, 2014, p. 40).

Em 1832, foi criada uma comissão com a finalidade de tornar viável a ideia de criar um direito comercial próprio consentâneo com seus interesses e desenvolvimento, o que deu ensejo a um projeto de lei, o qual somente foi sancionado em 1850 com a lei 556, que promulgava o Código Comercial brasileiro.

Embora o referido Código não tenha informado o que considerava mercancia (atos de comércio), o legislador cuidou de fazê-lo, no Regulamento 737/1850:



PARA LER

Art. 19. Considera-se mercancia:

§ 1º A compra e venda ou troca de efeitos moveis ou semoventes para os vender



por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso.

§ 2º As operações de cambio, banco e corretagem.

§ 3º As empresas de fábricas; de comissões; de depósitos; de expedição, consignação e transporte de mercadorias; de espetáculos públicos.

§ 4º Os seguros, fretamentos, risco, e quaisquer contratos relativos ao comércio marítimo.

§ 5º A armação e expedição de navios.

Vale ressaltar que o Código Comercial Brasileiro de 1850, que é o da época do Império, filiava-se à teoria dos Atos de Comércio, que não estava presente nos códigos espanhol e português. A influência do Código Brasileiro de 1850 foi apenas francesa e não de Espanha e Portugal, que seguiam outra linha de pensamento quanto ao Direito Comercial.

Sob o fulcro do Código Napoleônico, o Código Comercial de 1850 não supriu a evolução e o dinamismo social no que tange a práticas comerciais. Após a divulgação das ideias da teoria da empresa, mediante o código Civil italiano de 1942, gradualmente o direito brasileiro aderiu ao sistema italiano, o que resultou no Código Civil de 2002.

O Brasil filiou-se à teoria dos atos de comércio a partir do Código Comercial brasileiro de 1850, mas a abandonou e aderiu à teoria da empresa a partir do novo Código Civil de 2002.

O CC/02 revogou o Código Comercial de 1850. Contudo, a segunda parte do último, referente ao comércio marítimo, continua vigente.

Código Comercial de 1850:

Parte I – ~~“Comércio em geral”~~

Parte II – “Comércio Marítimo” **(VÁLIDO ATÉ HOJE!)**

Parte III – ~~“Das quebras”~~

Deste modo, o Código Civil vigente (CC/02) tratou, no Livro II, Título I, do “direito de empresa” (art. 966 a 1.195), regulamentando o regime jurídico do empresário individual (antigo comerciante) e da sociedade empresária (antiga sociedade comercial).

~~Comerciante~~ -> Empresário

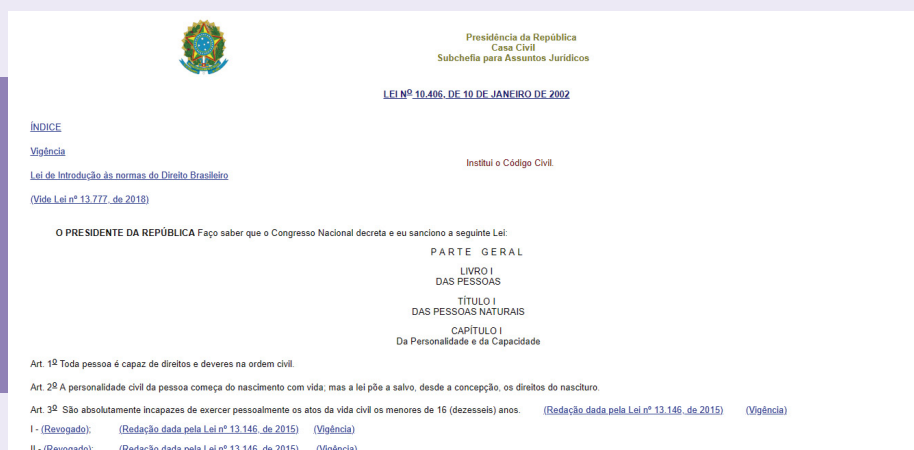
~~Sociedade Comercial~~ -> Sociedade Empresária



A mudança ultrapassa os aspectos terminológicos. O empresário não se restringe a quem pratica atos de comércio, mas consiste em todo aquele que “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”, conforme artigo 966 do CC/02



EXEMPLO



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm

Embora o CC/02 não defina expressamente o conceito de empresa, mas apenas o de empresário, facilmente depreende-se que empresa é uma atividade econômica organizada com a finalidade de fazer circular ou produzir bens ou serviços. Portanto, empresa é uma atividade, algo abstrato. Não é um lugar, nem uma pessoa (sujeito de direitos). O sujeito de direito é o titular da empresa, ou seja, quem exerce a empresa, logo o empresário, que pode ser pessoa física ou natural (empresário individual) ou pessoa jurídica (sociedade empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -EIRELI).



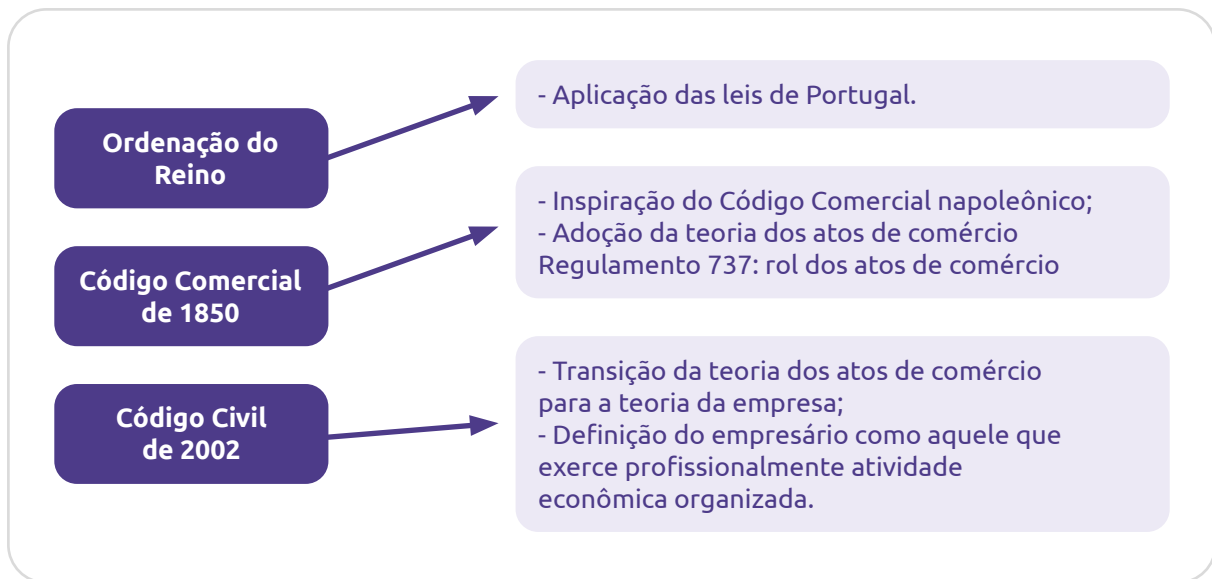
ATENÇÃO

Empresário (Art. 966, Código Civil -2002):

- * Pessoa Natural = Empresário Individual
- * Pessoa Jurídica = Sociedade Empresária EIRELI

Importante ressaltar o que determina o art. 2.037 do CC/02: “salvo disposição em contrário, aplicam-se aos empresários e sociedades empresárias as disposições de lei não revogadas por este Código, referentes a comerciantes, ou a sociedades comerciais, bem como as atividades mercantis”. Desta forma, as leis especiais referentes aos comerciantes, aplicam-se, também, aos empresários e sociedades empresárias, desde que, por óbvio, não tenham sido revogadas pelo código ou não se encontrem em desacordo com as estabelecidas naquela legislação ordinária.





A questão da nomenclatura: Direito comercial ou Direito empresarial?

Não raro se observa o uso da expressão 'direito comercial' no meio jurídico e profissional, sobretudo porque foi o comércio, desde a Antiguidade, a atividade precursora desse ramo do Direito. Todavia, a atividade empresarial não se restringe ao comércio, há outras além dele, como a indústria, os bancos, a prestação de serviços, dentre outros (RAMOS, 2014, p. 17).

Nesse sentido, também não deve confundir a figura do empresário com a dos comerciantes, na medida em que este é uma modalidade daquele.



ATENÇÃO

Empresário x Comerciante = Gênero x Espécie

Fontes do Direito Empresarial

Inicialmente, deve-se recordar o conceito de fontes do direito, sendo estas os vários modos de onde nascem, ou surgem, as normas jurídicas e os princípios gerais da ciência do direito. Tomando por base este conceito, costuma, ainda, a doutrina, dividir as fontes em materiais e formais, sendo aquelas os elementos que concorrem para a criação das leis e estas o alvo do direito comercial, ou seja, são a forma externa de manifestação do Direito Positivo, direito posto, aquele escrito nas normas.

Neste sentido, e visando uma melhor compreensão do assunto, as fontes do direito comercial estão divididas em dois segmentos: primárias ou diretas e subsidiárias ou indiretas.

As fontes primárias são as leis comerciais, assim tomando como parâmetro o direito brasileiro, é correto afirmar que o Código Comercial, as leis que lhe seguiram, os regulamentos baixados pelo Poder Público, os tratados internacionais.

Lei: material – proposição jurídica ou um conjunto de proposições jurídicas, ditada e publicada pelos órgãos do Estado competentes conforme a constituição; formal – toda disposição emanada dos órgãos do Legislativo na forma que, com base na



Constituição, é a regular para legislação. Exs.: Constituição Federal, leis em sentido estrito, medidas provisórias, regulamentos e Código Comercial, desde que tragam proposições jurídicas sobre Direito Comercial.

Já as fontes subsidiárias consistem na lei civil, nos usos e costumes, na jurisprudência, analogia e princípios gerais de Direito (art. 8, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro). Desta feita, inexistindo norma específica no Direito Comercial, deve-se recorrer a essas fontes, obedecendo-se, naturalmente, à ordem de sua enumeração.

Usos e Costumes mercantis: lembre-se que o direito comercial surgiu como um direito consuetudinário, baseado nas práticas mercantis dos mercadores medievais.

O direito consuetudinário não é uma fonte formal ou primária, porque não é uma fonte formal ou primária, porque não nasce do Estado, visto que é produzido pela vontade jurídica geral de uma coletividade manifestada normalmente mediante o uso.

Autonomia do Direito Empresarial

Analisados o histórico e as fontes do Direito Empresarial, percebe-se que hoje se pode considerar que o mesmo é um ramo autônomo do Direito. Apesar de parte da disciplina do Direito Empresarial estar prevista no Código Civil, outras leis específicas tratam do Direito de Empresa, como: Lei 11.101/05 (disciplina a recuperação de empresas e a falência); Lei 6.404/76 (que trata das Sociedades Anônimas) etc.

Autonomia formal ou legislativa: há um corpo próprio de normas destacado do direito comum – um código próprio (hoje, embasada no Código de Direito Comercial – Lei 556/1850 e no Código Civil – Lei No. 10.406/2002).

Autonomia substancial ou jurídica: possui princípios e características próprias, método próprio e vastidão – disciplina autônoma. Método indutivo; princípios: onerosidade, facilidade de formação e extinção das obrigações, pontualidade, facilidade de transmissão das obrigações, simplicidade das formas e cosmopolitismo.

Além disso, a Constituição Federal de 1988 assegura a autonomia do Direito Empresarial em seu artigo 22, I, quando estabelece a competência privativa da União para legislar sobre direito comercial (ou empresarial, conforme entendimento atual). Assim, como visto, o Direito Empresarial é o ramo do Direito que tem como objeto o estudo das regulamentações da atividade econômica dos sujeitos que atuam na produção e circulação de bens e prestação de serviços, com objeto próprio, a empresa.



ATENÇÃO

Será que se pode dizer que o direito empresarial perdeu a sua autonomia considerando que as normas empresariais se encontram dentro do Código Civil (CC/02)?

NÃO! O simples fato das normas de natureza comercial e das normas de natureza empresarial encontrarem-se dentro de uma única codificação não retiraram do direito empresarial a sua autonomia. Portanto, o direito empresarial/comercial cuida-se de um ramo autônomo do direito. (art.22, I da Constituição Federal)



Princípios do Direito empresarial

Visto que é no Direito empresarial que iremos encontrar as regras jurídicas especiais para a disciplina do mercado, revela-se fundamental que essas regras, em função de sua especialidade, estejam assentadas em uma principiologia própria.

Registre-se que os princípios funcionam como pilares do ordenamento jurídico. Na medida em que possuem um grau de generalidade e abstração maior do que das regras, eles promovem as diretrizes para a interpretação delas. Nesse contexto, enumera-se os seguintes princípios gerais que regem o Direito Empresarial:

1) Liberdade de iniciativa: A livre-iniciativa, segundo Fábio Ulhoa Coelho (2010), desdobra-se em quatro condições fundamentais para o funcionamento eficiente do modo de produção capitalista: (a) imprescindibilidade da empresa privada para que a sociedade tenha acesso aos bens e serviços de que necessita para sobreviver; (b) procura do lucro como principal meta dos empresários; (c) necessidade jurídica de proteção do investimento privado; (d) reconhecimento da empresa privada como polo gerador de empregos e de riquezas para a sociedade.

2) Liberdade de concorrência: Que busca proteger os empresários das intervenções do Estado, o qual, não obstante, vem restringindo cada vez mais o exercício da atividade econômica e criando mais obstáculos ao empreendedorismo (RAMOS, 2014, p. 25).

3) Garantia e defesa da propriedade privada: Revela-se pressuposto fundamental do regime capitalista de mercado, na medida em que, ausente a propriedade privada, não há mercado (RAMOS, 2014, p. 26).

4) Preservação da empresa: Busca promover a preservação da empresa, haja vista que esta implementa empregos, diminui a criminalidade, desenvolve a tecnologia e pesquisa, contribuindo para o sustento do estado democrático de Direito.

O Perfil Subjetivo (individual) de Empresa

A compreensão de empresário está prevista no art. 966 do CC/02:



ATENÇÃO

Art. 966 do CC/02:

“Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou a circulação de bens ou de serviços”.

1º - Quem exerce (pessoalidade): a atividade em nome próprio e não em nome alheio. Por exemplo: um garçom que trabalha em um restaurante de forma habitual, ele não é empresário, apesar de ele exercer uma atividade, não a faz em nome próprio, mas sim exercendo atividade em nome alheio. Na verdade, o garçom seria um preposto do empresário, conforme veremos a seguir.



2º - Profissionalidade (habitualidade): significa com habitualidade, de forma reiterada profissionalmente.

Dúvida: No caso de uma mulher chefe de família que sempre que o orçamento aperta, vende quentinhas na rua, será que ela é empresária? Não, porque ela não exerce a atividade profissionalmente, com habitualidade.

Se eu decidir vender meu computador para pagar uma dívida, sou empresário? Novamente a resposta é não, pois se trata de uma atividade comercial não habitual.

3º - Atividade econômica (objetiva o lucro): é econômica, pois almeja atender as necessidades de um terceiro, em busca de um retorno financeiro, ou seja, o lucro. Porém, nem todo aquele que deseja lucrar será empresário, como no exemplo dado acima.

4º - Organizada (organização dos fatores de produção): A atividade organizada é a que reúne todos os fatores de produção:

- Capital;
- Insumos (elementos necessários para desenvolver atividade).
- Mão-de-obra
- Tecnologia: domínio da técnica necessária para desenvolver a atividade econômica.

Gladston Mamede (2007, p. 32) ressalta que o elemento organização que caracteriza a empresa opõe-se ao trabalho essencialmente individualizado, pessoal, ainda que desempenhado em grupo, pois nesse não há divisão de categorias, não há ligação entre atos coordenados, nem definição de procedimentos voltados para a concretização de resultados otimizados. Mamede cita o exemplo de cinco rendeiras que se sentam na varanda, cada qual tecendo suas rendas, não constituem uma empresa; um ou mais pescadores que simplesmente saiam juntos diariamente para pescar.



X



Empresário não equivale a preposto

O empresário, seja ele na modalidade individual ou como sociedade, para atuar de maneira competitiva no mercado, pode utilizarse de **auxiliares** e **colaboradores**, figuras que o Código Civil denominou de prepostos (art. 1169 a 1178 CC/02).



Preposto é aquele que dirige ou pratica negócio empresarial por incumbência de outrem, que é o preponente (empresário). São representantes do empresário, incumbidos de seus negócios, desde o gerente até o vendedor de balcão, pois que todos obram em nome e por conta dele. Em outras palavras, os prepostos envolvem a mão-de-obra do empresário, enquadrando-se como um dos fatores de produção.

Por exemplo: sou empresário individual e contrato alguém para vender as mercadorias que eu estou produzindo. Esse alguém contratado é um preposto, que ajuda o empresário no desenvolvimento da atividade empresária.

Exemplo 2: Tenho problemas com minha tv por assinatura e aciono o atendente da Sky para resolver. Eles mandam um técnico para minha casa, que pode ser empregado de outra empresa que mantenha contrato de prestação de serviço com a sky.

Regras Gerais:

I. Poderes de representação típicos do mandato:

O contrato de preposição implica poderes de representação típicos do mandato. O mandato se refere a uma delegação de poderes, uma autorização que uma pessoa tem para agir em nome

Art. 1.169. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas.

Art. 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente.

Dessa maneira, não se admite ao preposto a possibilidade de delegar (transferir) poderes sem prévia autorização escrita do preponente (empresário), uma vez que as prerrogativas que a preposição lhe confere são **pessoais e intransferíveis**. Assim, o preposto não pode ultrapassar os poderes que lhe foram conferidos, nem pode substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente. Por exemplo: Imagina que o preposto (sem autorização escrita do preponente) assume uma obrigação qualquer em relação a um cliente, praticando um ato que viole o direito do cliente enquanto consumidor, o preposto pode ser acionado por essa obrigação.



II. Proibição dos prepostos fazerem concorrência:

Vale ressaltar que o preposto **não pode concorrer** com o preponente 'porque poderia, inclusive, praticar crime de concorrência desleal.



Art. 1.170 CC/02. O preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar por conta própria ou de terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo preponente os lucros da operação.



Em outras palavras, o preposto não pode concorrer com o preponente porque poderia, inclusive, praticar crime de concorrência desleal. Ora, não seria justo que um preposto trabalhasse em uma empresa, ali aprendendo todo o modo de produção e, no seu tempo livre, vendesse a mesma espécie de mercadoria, só que por ele próprio produzida, utilizando-se da experiência adquirida na empresa empregadora e da clientela formada por ela.

Nessa hipótese, o preposto estaria claramente praticando concorrência desleal contra a empresa para a qual exerce suas atividades.

Art. 195 da Lei 9279 de 1996: Comete crime de concorrência desleal quem:

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.



III. Responsabilidade dos prepostos

Quanto à responsabilidade dos prepostos, os preponentes (empresários) respondem pelos atos praticados por aqueles perante terceiros (clientes). Os preponentes podem voltar-se contra os prepostos caso estes tenham agido com **culpa**.

Parágrafo único do art. 1.177. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.

A culpa pode ocorrer em três modalidades: negligência (desinteresse, falta de atenção); imprudência (conduta irresponsável) e imperícia (falta de conhecimentos básicos para o exercício da profissão)

Exemplo 1: o empresário individual A desempenha uma atividade empresarial por meio de uma loja de calçados. No caso, os vendedores atuam como seus prepostos. O vendedor B, por negligência, vendeu um par de sapatos, mas entregou ao cliente dois pares. O cliente, é claro, não reclamou e foi embora, pagando apenas um par. O empresário A ficou no prejuízo por culpa do vendedor B. A pode cobrar de B o valor do par de sapatos não pago pelo cliente.

Exemplo 2: Ainda na loja de calçados, imagine a situação de um par de sapatos custa 55 reais, mas, no momento do pagamento, o vendedor, se confundiu, e falou que o preço era 75 reais. O cliente efetuou o pagamento. No dia seguinte, ficou sabendo do erro de vendedor, por meio da nota fiscal, e foi reclamar a devolução do dinheiro excedente. Quem vai responder por esse problema causado pelo preposto (vendedor) será o preponente (empresário). O dinheiro sairá do bolso do empresário, mas este pode descontar, posteriormente, do salário do preposto.

Por outro lado, caso o preposto atue com **dolo** (intenção de induzir alguém em erro), ou seja, ele quis mesmo prejudicar o preponente ou o terceiro (cliente), o preposto assumirá responsabilidade solidária com seu preponente, ou seja, os terceiros prejudicados podem exigir o cumprimento da obrigação total contra qualquer deles.

Exemplo: Preposto, sabendo que não tinha autorização de seu preponente, oferece ao cliente um brinde na compra de uma quantidade X de produtos. Após efetuar a compra, o cliente é informado que essa promoção não existe... o preposto afirma que 'Se enganou'. O cliente pode acionar tanto o preposto como o preponente para lhe entregar o referido brinde.

Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece sanções para os casos em que se comprova o caráter abusivo ou enganoso da publicidade e dispõe que, em regra, a responsabilidade pelos danos decorrentes dessas infrações é objetiva, ou seja, o fornecedor de serviços ou produtos responde independentemente da existência de culpa (art 14; 66 a 68 do CDC).





Resumindo:
Se os prepostos agem com culpa: devem indenizar em regresso o preponente.
Se os prepostos agem com dolo: respondem solidariamente com o preponente



IV. Adoção da Teoria da Aparência

Art. 1.178 CC/02. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito.

Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor.

Quando o ato é praticado dentro do estabelecimento empresarial e no cumprimento das atribuições próprias daquela contratação, os atos do empregado geram responsabilidade ao empregador, **independentemente** da existência de culpa. Por outro lado, se ele pratica o ato fora do estabelecimento empresarial, não haveria responsabilidade do empregador.

Observa-se, portanto, a “**teoria da aparência**”, que constitui princípio implícito que regula as relações empresariais com o objetivo de fornecer-lhes maior segurança jurídica. Busca-se, desse modo, proteger o terceiro de boa-fé, que, confiando na publicidade conferida a atos e informações prestadas, bem como na aparência legítima exteriorizada pelo sujeito, não poderá ser prejudicado em detrimento de quem aparentou legitimidade enquanto não a possuía (RAMOS, 2014, p. 125).

Sabendo da diferença entre empresário e preposto, vamos agora conhecer as espécies de empresário!

Espécies de empresário:

Podem ser titulares da empresa, isto é, da atividade empresária:

- a) **empresário individual:** em regra geral, é pessoa física (art. 44 do CC). Não há separação de patrimônio afetado pela atividade e pessoal, ou seja, todos os seus bens respondem pelos riscos do empreendimento. Possui responsabilidade ilimitada.



- b) **empresário coletivo = sociedade empresária:** em regra, é pessoa jurídica, ou seja, conjunto de pessoas (ou de bens, mas, no caso, são de pessoas) a quem a lei confere personalidade, capacitando-a a ser sujeito de direitos e obrigações. Sua principal característica, segundo Carlos Roberto Gonçalves (2003, p. 182), é a de que atuam na vida jurídica com personalidade diversa da dos indivíduos (sócios) que as compõem. Nesse caso, o sócio não pode ser considerado empresário para o Direito, a pessoa jurídica é quem é, possuindo patrimônio próprio (diferente do patrimônio dos sócios). No que se refere à responsabilidade, esta é definida em conformidade com a dos sócios, podendo ser limitada ou ilimitada.
- c) **EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada):** não é empresário individual nem sociedade, trata-se de nova espécie de pessoa jurídica constituída por uma única pessoa física, a qual reúne alguns requisitos previsto no CC/02 para constituir a EIRELI e, assim, ter seu patrimônio pessoal separado do patrimônio vinculado à empresa.





02

O Empresário e suas características





OBJETIVOS

O Empresário e suas características

Olá turma! Como é bom estar aqui!

“Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim”.

(Charles Chaplin)



ATENÇÃO

Termos-chave

Empresa. Empresário. Capacidade.





Imagem: Freepik

***Agora vamos analisar os requisitos
para ser empresário.***

Atividade empresarial:

Produção ou circulação de bens ou serviços de maneira organizada e habitual, para que o resultado dessa atividade seja colocado no mercado com o intuito lucrativo. Em outras palavras, o que faz alguém ser considerado empresário é a atividade econômica organizada e habitual dirigida para o mercado.

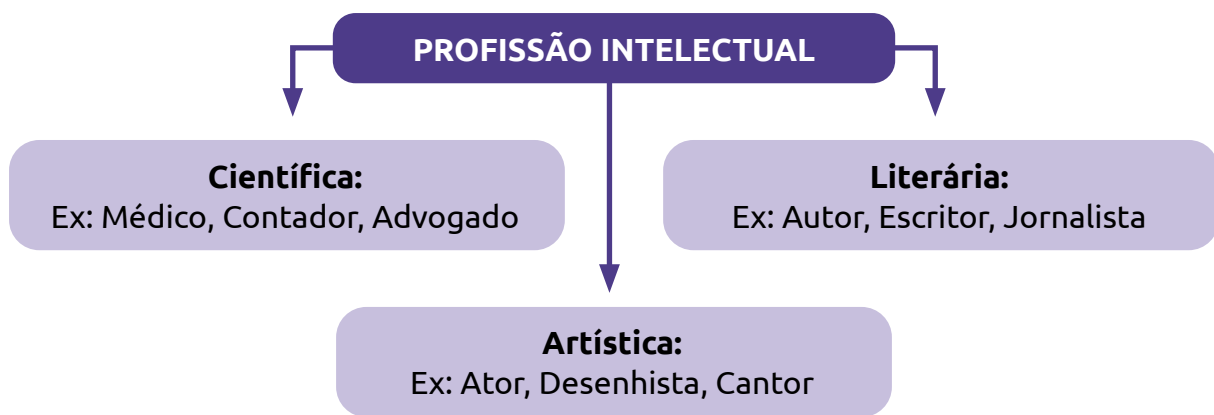
Os EXCLUÍDOS do conceito de empresário

A teoria da empresa, sem se preocupar em estabelecer; aprioristicamente, um rol de atividades sujeitas ao regime jurídico empresarial, não excluindo, a princípio, nenhuma atividade econômica de seu âmbito de incidência. Ocorre que existem agentes econômicos excluídos desse conceito: o profissional intelectual (profissional liberal), a sociedade simples e a sociedade cooperativa (assunto que será explicado detalhadamente na unidade V).

A situação específica dos profissionais intelectuais está disciplinada no art. 966, parágrafo único CC/02:

Art. 966, CC/02, parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa*.





PARA REFLETIR

O que é Elemento de empresa ??

Resp: ocorre quando a natureza pessoal da atividade cede espaço a uma atividade maior de natureza empresarial. No exercício da profissão intelectual, o essencial é a atividade pessoal do agente econômico. Se ele dá uma forma empresarial ao exercício de suas atividades, no sentido de impessoalizar sua atuação e passar a ostentar mais a característica de organizador da atividade desenvolvida. Assim, o elemento de empresa emerge quando a atividade empresarial se sobrepõe à atividade pessoal intelectual. Ex: O dono de uma Clínica veterinária investe em seu interior na construção e organização de um Pet Shop. (Se retirarem a parte da clínica, o dono continuará lucrando, ou seja, a atividade intelectual deixou de ser a central, e seu lucro não advém somente de sua uma atividade pessoal como veterinário.

Capacidade (art. 5º; 972 a 980 do CC/02):

Equivale a mesma da capacidade civil, ou seja, ao completar 18 anos ou antes pela emancipação. Registre-se que a emancipação consiste na antecipação da maioridade, ou seja, é a aquisição da capacidade civil antes da idade legal.

MENOR EMANCIPADO = MENOR CAPAZ

- **Requisitos: 16 anos completos**
- **Possibilidades (art. 5º CC/02):**
 - 1) Concessão dos pais mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor;
 - 2) Casamento;
 - 3) Emprego público efetivo
 - 4) Colação de grau de curso de ensino superior
 - 5) Estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.



Determinadas pessoas, por causa do cargo ou função que ocupam ou em virtude de algumas circunstâncias pessoais, não podem exercer atividade de empresário, mas se o fizer, responderão pelas obrigações contraídas.

Talvez seja a primeira vez que você esteja lendo sobre esse tipo de impedimento, mas certamente já conhece as regras e penalidades de um impedimento no jogo de futebol. São institutos que se aproximam, mas diferem em alguns aspectos. Vejamos:

Após um golaço, o bandeirinha levanta a bandeira e anula a jogada! Isso é de matar de raiva o jogador e, principalmente, o torcedor, não é



Porém, no direito empresarial, as consequências de um impedimento são diferentes! Conforme art. 973 CC/02, quem estiver impedido não poderá exercer atividade empresarial, mas caso se envolva, responderá como se empresário fosse, ou seja, os atos por ele praticados não serão nulos.

Podemos citar como impedidos de exercer a empresa:

- a) Agentes políticos: são as pessoas que ocupam posições no Poder Executivo, no Poder Legislativo e na cúpula do Poder Judiciário.
- b) Servidores Públicos: quem passou em concurso público por exemplo.
- c) Militares
- d) Falidos, enquanto não forem reabilitados (Lei de Falências, art. 195);
- e) Condenados
- f) Estrangeiro: só pode exercer a atividade empresarial individualmente se tiver o visto permanente.

Caso queira ser sócio, poderá desde que responda limitadamente e não exerça a administração, como todos os outros acima. Apenas podem ser sócios, desde que não exerçam a administração. Ou seja:

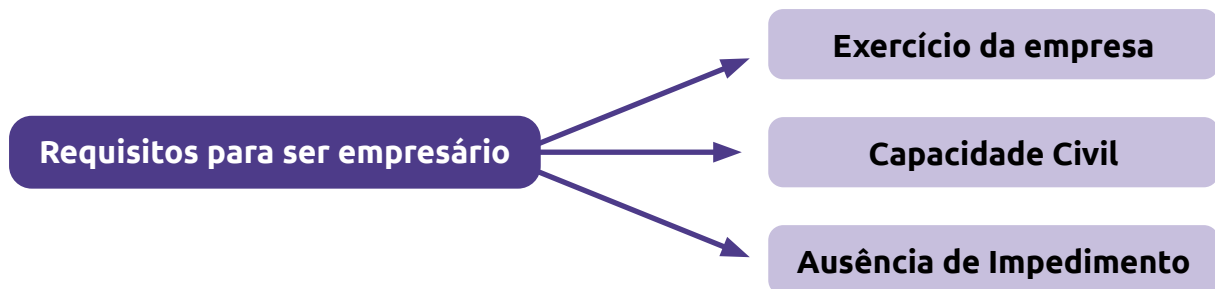
O impedimento se refere a 'ser empresário' $\neq$ 'ser sócio'

Desde que: Não pratique atos de gestão na sociedade; e que detenha responsabilidade limitada

Caso contrário, se o sócio, na condição de empresário impedido, exercer atividade de gestão, responderá com o seu patrimônio pessoal de forma ilimitada pelas obrigações contraídas, sem prejuízos de outras medidas de ordem administrativa e criminal que sejam cabíveis ao caso. Portanto, as obrigações contraídas por um empresário individual impedido não são nulas, mas válidas aos terceiros de boa-fé que com ele contratarem.



A **razão de ser dos impedimentos**: o legislador os impede, pois o exercício da atividade empresarial por essas pessoas pode comprometer a profissão delas, por isso só podem atuar como sócios, pois quem estar exercendo é a pessoa jurídica e não a pessoa física.



Empresário Individual

É comum uma pessoa decidir constituir uma empresa (atividade empresária) sozinha e organizá-la com seus próprios meios. Tal pessoa poderá optar por duas maneiras de exercer a atividade empresária sozinha: registrando-se como empresário individual ou constituindo uma empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI)², essa última de criação recente pela Lei 12.441/11 que entrou em vigor em 12 de janeiro de 2012.

Inicialmente, vamos analisar a questão do empresário individual. Toda e qualquer pessoa física que atenda aos requisitos descritos na seção anterior (exercício de atividade empresária, capacidade civil plena e ausência de impedimento) poderá praticar a atividade empresária, criando e organizando o negócio e para isso deverá se inscrever na Junta Comercial.



PARA REFLETIR

Registro na Junta Comercial é requisito para ser empresário individual?

Não, é requisito apenas para o empresário rural, pois é só a partir deste que ele será considerado empresário.

Art. 967 CC/02. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.

O registro, portanto, é uma obrigação legal imposta a todo e qualquer empresário (empresário individual ou sociedade empresária ou EIRELI), sob pena de começar a exercer a empresa irregularmente. Esse registro deve ser feito na Junta Comercial (Registro Público de Empresas Mercantis), que equivale a órgão administrativo estatal. Cada estado possui uma Junta Comercial³, tendo por função fazer o controle da atividade comercial desde o surgimento até a extinção da empresa. Qualquer modificação posterior, seja no nome empresarial, seja na quantidade de sócios de uma sociedade, seja na criação de mais uma filial, enfim, tudo deve ser comunicado



à Junta, mediante um aditivo, para dar publicidade a terceiros que queiram negociar com o empresário.

André Ramos (2014, p. 64) salienta, contudo, que o registro na Junta Comercial, embora seja uma formalidade legal imposta pela lei a todo e qualquer empresário individual ou sociedade empresária – com exceção daqueles que exercem atividade econômica rural, conforme veremos a seguir – não é requisito para a caracterização do empresário e sua consequente submissão ao regime jurídico empresarial. Nesse sentido, veja o Enunciado 199 do Conselho da Justiça Federal (CJF), aprovado na III Jornada de Direito Civil: “A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delimitador de sua regularidade, e não da sua caracterização”.

Vale ressaltar que tal registro não fará com que ele ganhe uma personalidade jurídica que será diferente da pessoa física. Ele nunca será considerado pessoa jurídica, já que não se enquadra em nenhuma das espécies de pessoa jurídica previstas no art. 44 do Código Civil, tampouco na recém-criada Empresa Individual de Responsabilidade Limitada que será analisada na unidade seguinte.

Portanto, o empresário individual é uma pessoa física que precisa de um registro no órgão competente para exercer sua atividade empresarial de maneira regular. De maneira semelhante, os advogados se registram na OAB e os médicos se registram no CRM, sem que com isso se tornem pessoa jurídica.

Não obstante, ao se registrar na Junta Comercial, o empresário deverá também realizar sua inscrição na Receita Federal, ocupando o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Por conta disso, muitos fazem uma ideia equivocada de que o empresário individual é pessoa jurídica. Na verdade, a existência desse número no CNPJ é apenas para fins tributários, como no caso do recolhimento do Imposto de Renda, em que o empresário individual será equiparado às pessoas jurídicas.

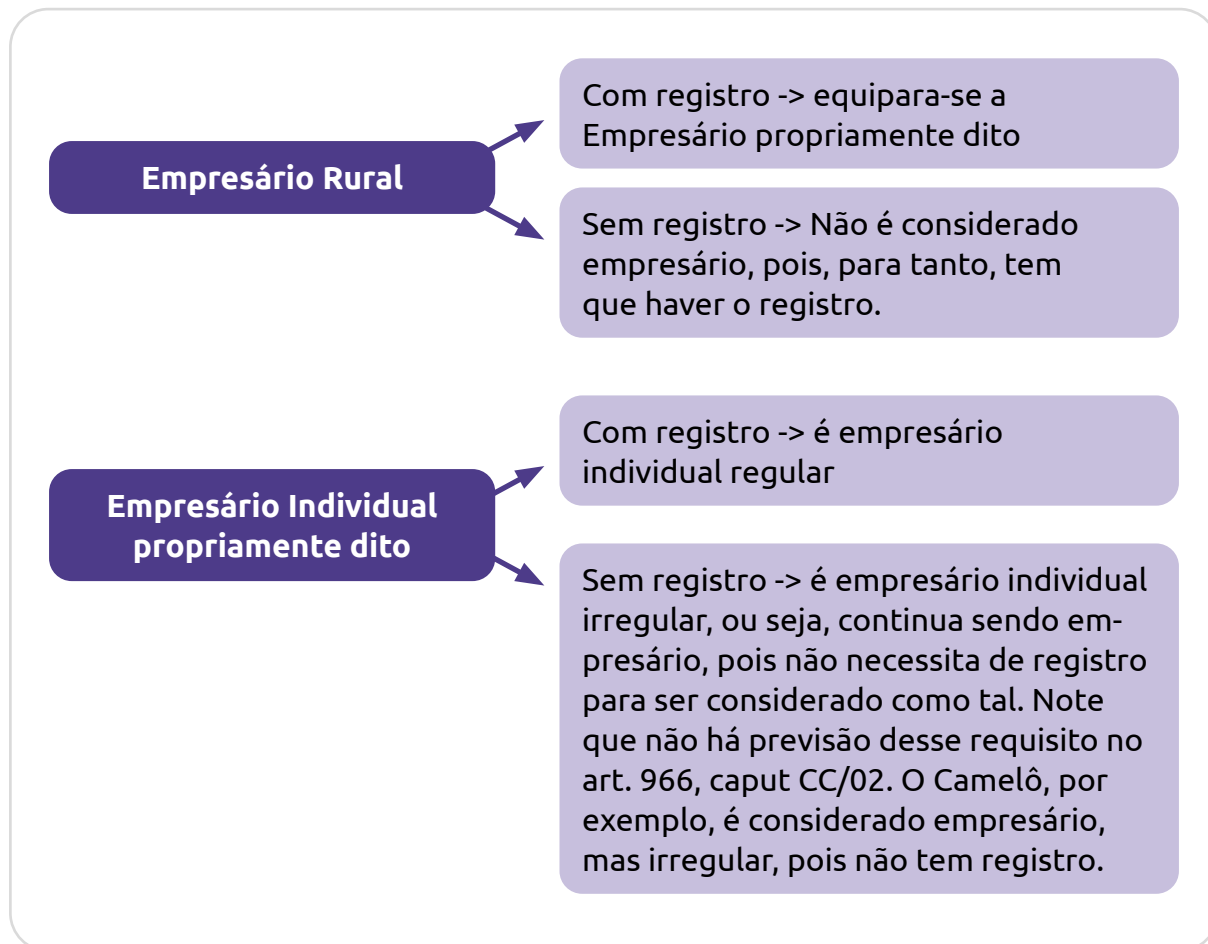
Embora possua CNPJ, empresário individual NÃO é pessoa jurídica!

Em se tratando de empresário rural, **o registro é facultativo, apenas no sentido de que não se torna irregular nessa modalidade com a ausência do registro.** Todavia, se ele quiser atuar como empresário individual propriamente dito, tem que registrar na Junta Comercial (Registro Público de Empresas Mercantis), submetendo-se as mesmas regras a que o empresário propriamente dito se sujeita.

Art. 971 CC/02. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.



Assim, o empreendedor rural só pode ser considerado empresário a partir do momento em que realiza o registro na Junta comercial. Caso não faça o registro, ao contrário do empresário individual, não estará na irregularidade, trata-se de uma faculdade de se tornar ou não empresário; mas, querendo, precisa registrar. Lembre-se: **para ser empresário rural, tem que haver o registro!**



Principais espécies de registro:

1. Matrícula: trata-se do registro dos chamados auxiliares do comércio (leiloeiros, tradutores públicos, interpretes comerciais, chefes de armazéns gerais), esses profissionais para que possam desenvolver atividade de maneira regular deverão estar registrados na junta comercial, e o nome dado a esse registro é MATRÍCULA.

2. Arquivamento: registro do ato constitutivo, alteração do ato constitutivo, dissolução da sociedade.

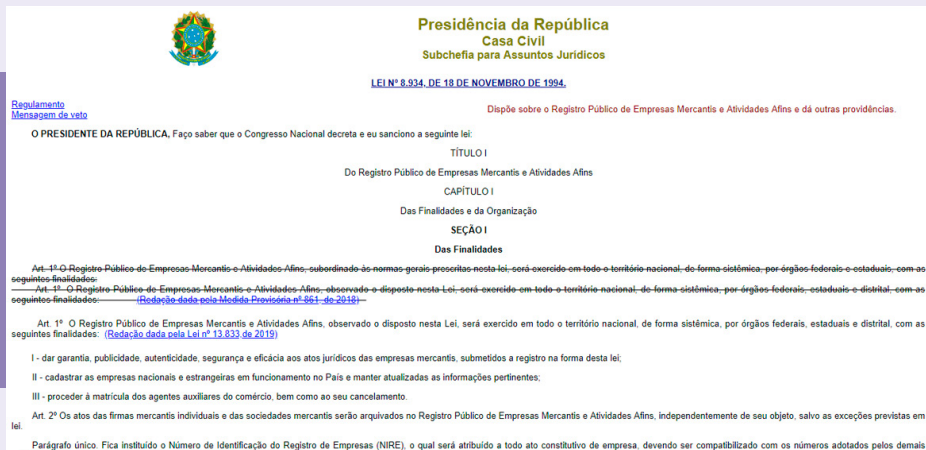
3. Autenticação: é o nome dado ao registro dos atos de escrituração contábil da sociedade, dos atos de escrituração do empresário individual. Quando essa escrituração, essa contabilidade é levada a registro da junta comercial, o nome desse registro chama-se autenticação. (Se é cumprida a obrigação, nós contamos com o favor da lei. Se promovemos o registro da sua escrituração, sua autenticação, nós poderemos utilizá-la como prova ao nosso favor.



Por outro lado, se nós não adimplimos a obrigação legal do registro, a partir da autenticação daquela escrituração contábil, nós não poderemos utilizá-la como prova ao nosso favor, no entanto ela pode ser utilizada contra nós). (art.32 da lei 8934/94 – lei de registro público de empresas mercantis).



EXEMPLO



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8934.htm

Empresário casado:

Nos termos do art. 978 CC/02, o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real.

Para entender melhor, observe o esquema seguinte:

Empresário casado pode:

Imagem: Freepik

Alienar
Gravar de ônus real



Os imóveis que integram
o patrimônio da empresa,
sem a outorga conjugal
(sem autorização do
esposo ou esposa)

Contudo, de acordo com os art. 979 e 980 CC/02, deverão ser registrados tanto no Registro Civil, como no Registro Público de Empresas Mercantis:

1) Pactos e declarações antenupciais do empresário;



- 2) Títulos de doação, herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade;
- 3) Sentença que tratar de separação judicial e ato de reconciliação.

Assim, se estes atos não forem devidamente registrados, o empresário não poderá opô-los contra terceiros.

Escrituração do Empresário

Nos termos do art. 1.179 CC/02, outra obrigação legal imposta a todo empresário é a necessidade de seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Os empresários devem manter um sistema de escrituração contábil periódico, bem como levantar anualmente dois balanços financeiros: o patrimonial e o de resultado econômico, mediante a escrituração em livros. (RAMOS, 2014, p. 76).

A obrigação é tão importante que a legislação falimentar (referente ao procedimento de falência) considera crime a escrituração irregular, caso a falência do empresário seja decretada (art. 178 e 180 da lei 11.101/2005 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm). Tendo em vista a importância dos livros, estes são equiparados a documento público para fins penais, sendo tipificada como crime a falsificação, no todo ou em parte, da escrituração comercial (art. 297, §2º, do Código Penal - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm).

Cabe pontuar que a escrituração do empresário compete a profissional específico: o contabilista, o qual deve ser legalmente habilitado, ou seja, encontrar-se devidamente inscrito no seu órgão regulamentador da profissão (art. 1.182 do CC/02). A exceção reside nos casos em que não exista contabilista habilitado na localidade, quando a tarefa da escrituração do empresário poderá ser exercida por outro profissional ou pelo próprio empresário.

Os **livros empresariais** classificam-se em:

a) Livros obrigatórios:

1. Comuns – Diário (exceção para o pequeno empresário). Sobre o que deve ser lançado no Diário, o art. 1.184 CC/02 explana:

Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.

§ 1º Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam



o período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados, para registro individualizado, e conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação.

§ 2º Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.

2. Especiais – Livros da SA Livro de Registro de Duplicata, dentre outros.

b) **Livros facultativos:** Razão, que classifica o movimento de mercadorias; Caixa, em que se controlam as entradas e saídas de dinheiro; Conta corrente, que é usado para as contas individualizadas de fornecedores ou clientes, dentre outros.

Obrigações:

- a) **Seguir ordem uniforme de escrituração (art. 1.179 CC/02):** ordem uniforme = razão contábil.
- b) **Autenticar na junta os livros obrigatórios (art. 1181):** antes de o empresário começar a usar o livro ele deve, regra geral, autenticar. Na capa do livro se insere o termo de abertura do livro empresarial, autentica-se carimbando ou assinando e ao final se coloca um termo de encerramento, para quando o empresário finalizar o livro, puder começar outro.
- c) **Conservar a escrituração no prazo de prescrição (art. 1194):** conservar tudo o que se tem. Guardar os livros empresariais.

Sistemas legais de escrituração:

Francês: a lei impõe ao empresário a necessidade de escriturar suas relações jurídicas, os livros que devem escriturar e o método de sua escrituração.

Suíço: a lei impõe ao empresário a necessidade de escriturar suas relações jurídicas, deixando-o livre quanto aos livros que deve escriturar e ao método de escrituração.

Alemão: a lei impõe a necessidade de o empresário escriturar a suas relações jurídicas e os livros a que deve escriturar; porém deixa-o livre quanto ao método de escrituração.

A eficácia probatória dos livros empresariais:

Acerca da eficácia probatória, ou seja, os efeitos que geram a escrituração dos livros para geração de prova, prevê o art. 417 do Novo Código de Processo Civil:



Art. 417. Os livros empresariais provam contra o seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.

Assim, a eficácia probatória dos livros empresariais contra o empresário opera-se independentemente de os mesmos estarem corretamente escriturados. Nada impede, todavia, que o empresário demonstre, por meio de outros meios de prova, que os lançamentos constantes daquela escrituração que lhe é desfavorável são errôneos (RAMOS, 2014, p. 81).

Por outro lado, para que os livros façam prova a favor do empresário, é necessário que eles estejam regularmente escriturados, conforme o art. 418 do NCPC:

Art. 418. Os livros comerciais que preencham os requisitos exigidos por lei, provam também a favor do seu autor no litígio entre empresários.



QUESTÕES COMENTADAS

✓ QUESTÃO 01

Considerando a evolução histórica do direito empresarial, assinale a opção correta.

- a) A teoria dos atos de comércio foi adotada, inicialmente, nas feiras medievais da Europa pelas corporações de comerciantes que então se formaram.
- b) A edição do Código Francês de 1807 é considerada o marco inicial do direito comercial no mundo.
- c) Considera-se o marco inicial do direito comercial brasileiro a lei de abertura dos portos, em 1808, por determinação do rei Dom João VI.
- d) É de origem francesa a teoria da empresa, adotada pelo atual Código Civil brasileiro.
- e) O direito romano apresentou um corpo sistematizado de normas sobre atividade comercial.

Resposta: c.

A-F a teoria dos Atos de Comércio surgiu bem depois das feiras mercantis, que marcaram a primeira fase do Direito Comercial. B-F o Código Comercial francês de 1808 é o marco da fase objetiva do Direito Comercial, mas o ramo jurídico já existia desde a fase subjetiva; C-V história do Direito Comercial brasileiro iniciou em 1808, com a chegada da família real portuguesa no Brasil e



com a abertura dos portos às nações amigas. Isso ocorreu através da Carta Régia de 28 de janeiro desse mesmo ano. Foi com tal evento que o Brasil começou a ter efetivamente um comércio regulamentado, já que antes disso a atividade comercial era mínima. D-F devido à evolução da atividade comercial, surgiu no direito italiano a teoria da empresa, que supriu as lacunas no direito comercial e ampliou significativamente o objeto de estudo desse ramo jurídico. E-F o direito romano não tinha um direito comercial sistematizado, pois possuía legislações esparsas, e grande parte da regulamentação do comércio estava no Código Civil.

✓ QUESTÃO 02

- () No Código Comercial do Império do Brasil, adotou-se, por influência dos códigos francês, espanhol e português, a teoria dos atos de comércio, no que se refere à sua abrangência e aplicação.

Falsa.

O Código Comercial Brasileiro de 1850, que é o da época do Império, filia-se a teoria dos Atos de Comércio, que não estava presente nos códigos espanhol e português. Esse é o erro da afirmativa. A influência do Código Brasileiro de 1850 foi apenas francesa e não de Espanha e Portugal, que seguiam outra linha de pensamento quanto ao Direito Comercial. Hoje, o Brasil, após o Código Civil de 2002, segue a influência do Direito italiano e filia-se à Teoria da Empresa.

✓ QUESTÃO 03

- () Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica para a produção ou circulação de bens e serviços.

Falsa.

Na verdade, a alternativa está incompleta, pois faltou o requisito da organização.

✓ QUESTÃO 04

- () É considerada empresária a pessoa que, exercendo profissão intelectual de natureza artística, contrate empregados para auxiliá-la no trabalho.

Falsa.

O parágrafo único do art. 966 retira as atividades intelectuais da condição de empresária, mesmo que tenha auxiliares ou colaboradores. Somente será empresária a atividade intelectual se constituir o elemento de empresa.



✓ QUESTÃO 05

- () Marcos exerce atividade rural como sua principal profissão. Nessa situação, Marcos poderá requerer, observadas as formalidades legais, sua inscrição perante o Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, equiparandose, após a sua inscrição, ao empresário sujeito a registro.

Verdadeira.

O Código Civil deu tratamento diferenciado para o rural, em virtude da sua maior dificuldade de exercer sua atividade. Assim, o art. 971 faculta o rural a se inscrever na Junta Comercial, mas se optar por fazê-lo se torna empresário como qualquer outro.

✓ QUESTÃO 06

- () O menor com dezesseis anos idade que não seja emancipado somente poderá dar início a empresa mediante autorização de juiz.

Falsa.

O indivíduo de 16 ou idade inferior não poderá, em nenhuma hipótese, dar início à atividade empresarial. O que se conclui da interpretação conjunta dos art. 972 e 974 é que ele só poderá continuar a empresa, neste caso específico do menor, se receber por herança.

✓ QUESTÃO 07

De acordo com o Código Civil, o exercício da atividade empresarial por pessoa legalmente impedida

- a) implica a nulidade dos atos praticados.
- b) implica a anulabilidade dos atos praticados.
- c) resulta no dever de responder pelas obrigações contraídas.
- d) consiste em crime contra a administração da justiça.

Resposta: c.

Sob o fulcro do art. 973 CC/02, se uma pessoa impedida de ser empresária, mesmo assim exercer a atividade, "responderá pelas obrigações contraídas". Revela-se uma solução justa dada pelo legislador, na medida em que protege o terceiro de boa-fé, que pode desconhecer o impedimento do que pratica o ato.

Na próxima aula discutiremos acerca das peculiaridades da sociedade empresária e as consequências de sua personalidade jurídica no Direito empresarial. Esperamos que você tenha aproveitado todos os recursos disponíveis e fique atento aos prazos, pois ainda há tempo para reforçar e fortalecer seu aprendizado. **Bons estudos!**





03

Estabelecimento Empresarial





OBJETIVOS

Estabelecimento Empresarial

Sabendo que a motivação é uma arma poderosa para alcançarmos o sucesso em qualquer área da vida, estabeleçam a meta da realização profissional e, assim, persistam e não desistam de seus sonhos. Para tanto, vamos agora aprender, nesta unidade, sobre a figura do Estabelecimento Empresarial, analisando seu conceito, condições de eficácia, efeitos e atributos.



ATENÇÃO

Termos-chave

Estabelecimento Empresarial. Contrato de Trespasse. Clientela. Aviamento.





Imagem: Freepik

Estabelecimento Empresarial (art. 1142 a 1149 do CC/02)

O estabelecimento comercial (ou empresarial) é também denominado de fundo de comércio, por influência dos escritores franceses (fonds de commerce), e de azienda, por inspiração dos juristas italianos. Nosso Código Civil de 2002 designa-o como 'estabelecimento' apenas:

Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens (materiais e imateriais) organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.

De acordo com o referido artigo, compõe-se o estabelecimento comercial de elementos corpóreos e incorpóreos, que o empresário une e organiza para o exercício da empresa. Trata-se de um bem jurídico¹ móvel, não consumível² e não fungível³. Sendo objeto de direito, constitui propriedade do empresário ou da sociedade empresária, que é a sua dona (sujeito de direito).

O estabelecimento nada mais é do que o conjunto de bens necessário para o exercício da atividade empresarial. Considerando-o como complexo de bens, vê-se que o estabelecimento empresarial assume um **caráter** marcadamente **instrumental** para o desempenho da atividade. Os bens materiais e imateriais conjugados no estabelecimento não perdem cada um deles a sua individualidade singular, embora todos unidos integrem um novo bem.

¹ Esse objeto pode consistir em coisas, em ações humanas (nas relações obrigacionais) e em certos atributos da personalidade.

² Bens que permitem o uso contínuo sem destruição imediata da substância, conforme art. 86 CC/02. Ex: escultura famosa.

³ Bens móveis que não podem ser substituídos por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade, segundo art. 85 CC/02.



De outro giro, visto que o estabelecimento é um conjunto de bens dotado de **organização**, os bens que o compõem constituem um todo articulado, organizado, conexo. É essa organização que o empresário confere aos bens componentes do que vai fazer com que este, na qualidade de complexo de bens, se diferencie, sobretudo desses bens individualmente considerados.

Estabelecimento: conjunto de bens	
Materiais	Imateriais
Computadores; resmas de papel; impressoras, etc.	Ponto comercial; tecnologia; nome empresarial ⁴ ; marca.

Cite-se como exemplo uma sociedade que tem como objeto da atividade empresarial uma Gráfica, tem como bens materiais (tangíveis): computadores, resmas de papel, impressoras, veículos utilizados para escoar o que a gráfica produz. E como bens imateriais (intangíveis) terá: ponto empresarial, marca, patente, tecnologia, o nome empresarial. Acontece que esses bens, quando são aglutinados, transformando-se em um conjunto, formam um todo unitário chamado de estabelecimento empresarial.

O **ponto comercial**, segundo Rubens Requião (2014, p. 369), é o lugar do exercício da empresa em determinado espaço, em que está situado o estabelecimento comercial, e para o qual se dirige a clientela. Potanto, o ponto comercial é apenas um dos elementos que compõem o estabelecimento empresarial, o qual, como observado, composto também de outros bens materiais (equipamentos, máquinas, etc) e até de bens imateriais (marca, patente de invenção etc).

Contudo, não se deve entender o ponto comercial apenas como local físico, tendo em vista a extensão dos negócios realizados via internet.

Assim, o ponto pode ter existência física ou virtual. No caso do ponto virtual, ele equivaleria ao endereço eletrônico por meio do qual os clientes encontram o empresário.

De outro giro, visto que o estabelecimento é um conjunto de bens dotado de organização, os bens que o compõem constituem um todo articulado, organizado, conexo. É essa organização que o empresário confere aos bens componentes do que vai fazer com que este, na qualidade de complexo de bens, se diferencie, sobretudo desses bens individualmente considerados.

Vale ressaltar a importância do ponto comercial, pois o local em que a atividade empresarial é desenvolvida é decisivo para o sucesso ou não de um determinado empreendimento. Imagine um ponto comercial no centro de Fortaleza ou na 25 de Março de São Paulo, onde o comércio varejista é pujante e que atrai uma quantidade enorme de consumidores haja vista os preços razoáveis dos produtos ofertados. Um ponto em um desses logradouros é bastante valorizado, o que não aconteceria se fosse em um local pouco movimentado. Exatamente por isso o ponto empresarial é revestido de grande importância, sendo efetivamente protegido pela legislação

⁴ O nome empresarial do titular do estabelecimento não pode ser incluído na alienação do estabelecimento, conforme art 1164 CC/02: "O nome empresarial não pode ser objeto de alienação".



pátria. Quando se protege o ponto empresarial está se buscando proteger a clientela, a freguesia, dentre outras vantagens de mercado.

Obs.: O legislador (lei 8245/91) previu a possibilidade de o locatário impetrar uma ação renovatória em face do locador na circunstância deste tentar passar a usufruir das vantagens de mercado formadas por aquele (locatário). Ora, imagine a situação em que um empresário alugue um imóvel para exercer sua atividade empresarial de lavanderia, por exemplo. Essa atividade se revelou muito lucrativa, o que fez ‘crescer os olhos’ do locador, que pensou “Essa atividade lucrativa só existe porque existe o meu imóvel para ela acontecer, não vou permitir a renovação do contrato de locação e farei eu mesmo a atividade do empresário locatário”. Para a preservação da empresa, o legislador protegeu o ponto comercial do locatário das artimanhas de um locador invejoso, desde que obdecidos certos requisitos legais previstos na lei 8245/91.

Por outro lado, o estabelecimento não se confunde com a empresa, uma vez que esta corresponde a uma atividade. Na mesma esteira de raciocínio, o estabelecimento não se confunde com o empresário, haja vista este ser uma pessoa física ou jurídica que explora essa atividade empresarial e é o titular dos direitos e obrigações dela decorrentes.



PARA LER

Estabelecimento $\neq$ Ponto Comercial $\neq$ Empresa $\neq$ Empresário

Embora estabelecimento, ponto comercial, empresa e empresário não se confundam, são conceitos que se interrelacionam: “[...] o estabelecimento, como complexo de bens usado pelo empresário no exercício de sua atividade econômica, representa a projeção patrimonial da empresa ou o organismo técnico-econômico mediante o qual o empresário atua” (RAMOS, 2014, p. 99).

Vale ressaltar que a titularidade de estabelecimento não é elemento definidor de empresário ou de sociedade empresária.

Obs.: Contratos não integram o estabelecimento comercial:

Os contratos não são bens e, a rigor, escapam do âmbito do estabelecimento comercial, mas são elementos da empresa. No exercício da empresa, de que é o estabelecimento (ou fundo de comércio) instrumento. O empresário é levado a firmar diversos contratos. Esses contratos se referem ao funcionamento desse instrumento de ação, mas não o integram. Nas palavras de Rubens Requião (2014, p.369):

Não podemos a rigor, por exemplo, afirmar que os contratos de trabalho constituem elementos do fundo de comércio. Eles dizem respeito ao exercício da empresa, ajustados que são pelo empresário.



Não podemos confundir a empresa com o fundo de comércio, pois aquela, repetimos, é o exercício da atividade do empresário e este é o instrumento daquele exercício. Ao lado do fundo de comércio, que é instrumento, os contratos são elementos do exercício da empresa.

Por meio dos contratos, o empresário exerce a atividade. Logo integram a empresa, e não o estabelecimento.

Natureza jurídica do estabelecimento empresarial

Na lição de Maria Helena Diniz (1998), a natureza jurídica é o significado último dos institutos jurídicos, podendo ser tida como a afinidade que um instituto jurídico tem em diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, podendo nela ser incluído a título de classificação. Dessa maneira, determinar a natureza jurídica de um instituto consiste em estabelecer a sua essência para classificá-lo. Em outras palavras, consiste no regime jurídico em que o estabelecimento se enquadra.

A peculiar figura jurídica do estabelecimento, formada de bens que, unidos, oferecem em seu conjunto nascimento a um novo bem, conforme já se destacou, tem desafiado a argúcia dos juristas para enquadrá-la nas tradicionais categorias jurídicas. A doutrina brasileira majoritária, sob influência da doutrina italiana, considera o estabelecimento empresarial uma **universidade de fato**, ou seja, constitui um conjunto de bens que se mantêm unidos, destinados a um fim, por vontade e determinação de seu proprietário, e não em virtude de disposição legal. (REQUIÃO, 2014, p. 353).

Rubens Requião (2014, p. 353) cita como exemplo a biblioteca e o rebanho, que são compostos de unidades que permanecem unidas pela vontade do proprietário, que pode desintegrá-las a qualquer momento. Por conta disso, o fundo de comércio se apresenta como um bem.

A universalidade de fato não se confunde com a universalidade de direito, a qual somente se constitui por força de lei. Cite-se como exemplo a herança, que compõe uma universalidade antes de efetuada a partilha respectiva aos herdeiros. Falta ao estabelecimento, no direito brasileiro, uma estrutura legal que o enquadre na categoria de universalidade de direito.

Natureza Jurídica: **Universidade de fato** (# Univ. de direito)

Decorre da vontade do empresário

Vontade da lei

Conjunto de bens com destinação unitária, ou seja, de forma unificada, podem ser objeto de negócio jurídico

O estabelecimento, de forma unitária, pode ser objeto de negócios jurídicos, sejam eles negócios:



Translativos:

Vem de transferência, de transmissão. Implica a transferência da propriedade.
Ex: alienação, doação, etc. (art.1143 do CC/02)

Constitutivos:

São negócios em que não há a transferência da propriedade.
Por exemplo: aluguel, arrendamento¹, usufruto², etc. (art.1143 do CC/02)

¹ É semelhante ao contrato de locação (aluguel), mas possui uma cláusula com opção de compra ou renovação do contrato, deduzidas as parcelas já pagas.

² É o direito real de fruir as utilidades e frutos de uma coisa, enquanto temporariamente destacado da propriedade. Pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. Aquele a quem é concedido o usufruto não tem a propriedade do bem, apenas a posse para o fruir as utilidades e benefícios.

Contrato de Trespasse

É o contrato oneroso cujo objeto é a transferência do estabelecimento empresarial.

Quem aliena o estabelecimento é o trespasante (alienante);

Portanto, são partes no trespasse: o Trespasante (alienante do estabelecimento) e o Trespasatário (adquirente do estabelecimento). É preciso que haja a transmissão dos elementos essenciais para a continuidade da atividade empresarial pelo trespasatário. Mero ato de passar o ponto comercial não caracteriza o trespasse. Nesse sentido, estabelece o Enunciado¹ 233 da III Jornada de Direito Civil: “A sistemática do contrato de trespasse delineada pelo Código Civil nos arts. 1.142 e ss., especialmente seus efeitos obrigacionais, aplica-se somente quando o conjunto de bens transferidos importar a transmissão da funcionalidade do estabelecimento empresarial”.

Vale ressaltar que o estabelecimento empresarial é considerado uma das maiores garantias para os credores. Por que? Porque todos os seus elementos possuem um valor patrimonial que pode ser dissolvido em recursos para pagar o credor. Já imaginaram quanto custa o valor apenas da marca da Nike? Imaginem o complexo total de bens da sociedade a qual ela pertence.

Exemplo: Carlos é sócio de uma sociedade empresária, que precisa levantar recursos junto a uma instituição financeira (banco), tendo em vista problemas no fluxo de caixa, necessidade de saldar alguns compromissos com fornecedores, dentre outros. Por conta disso, Carlos vai ao banco tentar levantar crédito. O gerente diz que quer fazer uma visita ao seu estabelecimento, pois ele sabe que se a linha de crédito não for paga pela sociedade, ele tem de onde tirar o dinheiro, pois o estabelecimento empresarial sempre será uma das principais garantias aos credores.

¹ Decorre do resultado de debates sobre temas controversos a partir do entendimento de pensadores do direito que dominam aquela determina área do conhecimento.





EXEMPLO

Professora, como o estabelecimento pode ser uma garantia de crédito ao credor se, a qualquer momento, ele pode ser alienado pelo empresário?

Sim, é verdade que o estabelecimento pode ser alienado pelo empresário¹, mas, para que esse negócio jurídico seja realizado de maneira válida e eficaz, é imperativo que ele esteja em harmonia com as condições de eficácia apontadas pelo CC/02, as quais serão analisadas a seguir.

Condições de Eficácia

Condições de eficácia do contrato de trespasse são os pressupostos para que a ele produza efeitos no mundo jurídico perante os seus destinatários e a terceiros. O termo 'eficácia' gira em torno do grau de exigência ou alcance de efeitos no âmbito de concreção jurídica. Sobre esses pressupostos de eficácia do contrato, estabelece o art. 1.144 CC/02:

Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de **averbado** à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária (ou da EIRELI), no Registro Público de Empresas Mercantis, e de **publicado na imprensa oficial**.

A produção de efeitos quanto a terceiros é denominada de efeito erga omnes, ou seja, efeitos que atingem a todos. Para tanto, é preciso promover o registro do negócio jurídico abaixo da inscrição original e a publicação no Diário Oficial. Assim, para que o contrato produza efeito entre as partes, não há necessidades dessas formalidades, mas para que ele produza efeitos para todas as pessoas, o registro e a publicação se fazem fundamentais.

Exemplo: A aliena seu estabelecimento empresarial para B, celebrando um contrato de trespasse. A partir do momento que A e B assinam esse contrato, há o surgimento de eficácia entre as partes, este instrumento contratual faz lei entre as partes. Mas A e B não podem opor esse negócio jurídico a terceiro, porque como é que o terceiro poderia saber da celebração desse negócio entre A e B, não se pode cobrar algo dele, que ele não tinha como saber. Por outro lado, se A e B registram esse negócio jurídico no RPEM, e levam à publicação no diário oficial, a partir desse momento, aquele ato negocial passa a gozar de eficácia erga omnes, porque foi conferida publicidade ao negócio jurídico celebrado, dando conhecimento a terceiros.

¹ Leia-se empresário como gênero das espécies: empresário individual, sociedade empresária e EIRELI.



Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.

Conforme o art. 1.145, se você pretende alienar o seu estabelecimento empresarial, primeiramente precisa pagar todos os seus credores. Caso você ainda não tenha pago todos os seus credores, ainda assim pode alienar o estabelecimento, desde que tenha patrimônio suficiente para pagá-los. E se não tiver patrimônio suficiente para pagá-los? Existe ainda uma terceira possibilidade: ainda poderei alienar o estabelecimento se obtiver a autorização **unânime** dos credores.

Importante esclarecer que essa autorização poderá ser realizada de maneira expressa (por escrito) ou tácita (silenciosa). A autorização tácita ocorre quando, por exemplo, o empresário envia uma notificação sobre a pretensão de venda do estabelecimento para todos os credores e decorrido 30 dias, eles não manifestam qualquer negativa ou embaraço.

1º) Pagar os credores; (Se não estiverem pagas todas as dívidas);

2º) Verificar se os bens restantes são suficientes para o pagamento dos credores; (Se os bens restantes não forem suficientes);

3º) Pedir autorização dos credores: notificação deles para que se manifestem no prazo de até 30 dias (tem que ser unânime);

4º) Registro e Publicação.

Caso o empresário aliene o estabelecimento sem respeitar as condições do art. 1.145 do CC/02, estará praticando um ato considerado pela lei como um ato de falência, conforme art. 94, III da lei 11.101/2005 (lei de falência e de recuperação judicial). Veja:

Art. 94.

Será decretada a falência do devedor que:

(...)

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial:

(...)

c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;



Possibilidade de penhora do estabelecimento:

Muito já se discutiu sobre a viabilidade do penhor do estabelecimento comercial desde que Carvalho Mendonça apresentou sobre o tema tese no Congresso Jurídico Nacional de 1922, no sentido de aconselhar que a lei o admita, regulando-o com a máxima cautela.

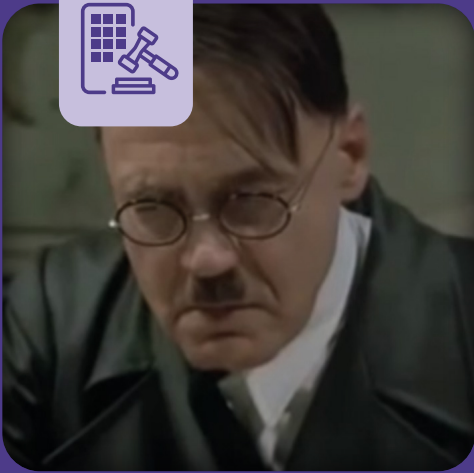
Em contrapartida, o professor Oscar Barreto Filho sustentou que o estabelecimento comercial, em si, não pode ser objeto de penhor, na falta da lei expressa que o autorize, pois esta é a garantia de cuidados para a proteção de terceiros de boa-fé, inclusive organizando adequado sistema de publicidade sobre o ato (REQUIÃO, 2014).

Em que pese as discussões doutrinárias, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento consolidado de que é possível a penhora de estabelecimento empresarial:

Súmula 451 STJ: “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”.

Sabendo das condições do contrato de trespasse, vejamos agora o seguinte vídeo, que simula os possíveis problemas de alguém que não respeitou essas condições antes de comprar o estabelecimento.

 **VÍDEO**



Tempo: 04 min



**A lojinha do ditador-
Direito Empresarial/
Trespasse**

Canal: Rodrigo Nunes

>>> CLIQUE NESSA IMAGEM E ASSISTA AO VÍDEO <<<

<https://www.youtube.com/watch?v=0nATDWln0V4>

Efeitos do Contrato de Trespasse

a) Sucessão Empresarial:



Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento **responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência**, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

O trespasatário (adquirente) do estabelecimento responde pelas dívidas anteriores ao trespasse, desde que regularmente contabilizadas, isto é, constantes da escrituração regular do alienante, pois foram essas as dívidas de que o adquirente teve conhecimento quando da efetivação do negócio, normalmente precedido de procedimento denominado due diligence (medidas investigatórias sobre a real situação econômica do empresário alienante e dos bens que compõem o seu estabelecimento empresarial).



EXEMPLO

Quer dizer, professora, que se um empresário alienar o estabelecimento empresarial para mim, eu, adquirente, vou ser o novo responsável pelas dívidas que ele assumiu no desenvolvimento da atividade naquele estabelecimento? Sim, desde que devidamente contabilizadas.

CASO CONCRETO: Imagine que Paulo está negociando a alienação do estabelecimento empresarial, acompanhado de um advogado, já sabe que, como regra, o adquirente do estabelecimento empresarial passa a responder pelas dívidas anteriores ao negócio jurídico. Sabendo disso, ainda durante as discussões de negociação desse contrato de trespasse, Paulo resolve ir à Junta Comercial para certificar-se do montante real das dívidas relacionadas a esse estabelecimento empresarial. Isso porque Paulo deseja operar, formalizar esse negócio a partir de uma base sólida, tendo ciência do montante das eventuais dívidas existentes, pois, ciente dessas informações, ele terá subsídios para estabelecer uma negociação razoável, justa e compatível. Ocorre que, alguns meses após formalizado o contrato de trespasse, começam a bater na porta de Paulo uma série de credores cuja existência ele desconhecia, somando um montante diferente e bem superior ao que havia tomado conhecimento.

Pergunta-se: será que Paulo poderá ser cobrado por essas dívidas, cuja existência não tinha como saber, já que essas dívidas não estavam contabilizadas, não estando informadas na Junta Comercial? NÃO, se não foi conferida publicidade à existência dessas dívidas, não é possível que elas sejam cobradas do adquirente. Lembre-se de que para que esteja dotada de eficácia erga omnes, é necessário que haja anteriormente a publicidade em relação às obrigações existentes. **Portanto, pelas dívidas não contabilizadas responde apenas o trespasante.**

Pois bem. Embora o trespasatário assuma as dívidas contabilizadas, o **trespasante** (alienante) **fica solidariamente responsável por elas durante o prazo de um**



ano. Referido PRAZO, contudo, será contado de maneiras distintas a depender do vencimento da dívida em questão:

I. Dívida já vencida:

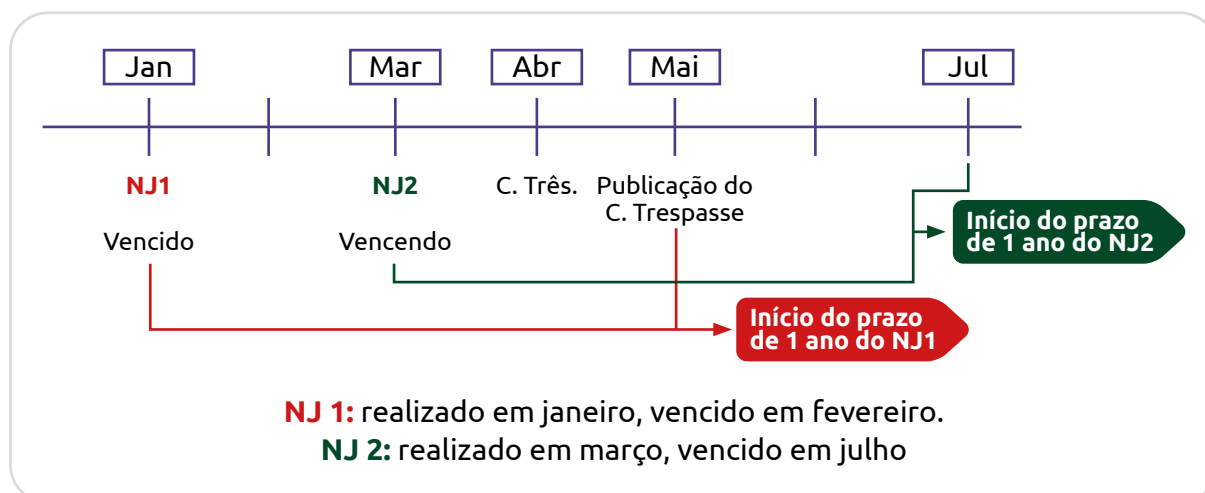
o prazo é contado a partir da publicação do contrato de trespasse.

II. Dívida vincenda:

o prazo é contado a partir do dia do vencimento da dívida.

Assim, se um negócio jurídico qualquer (exemplo: compra e venda de máquina) for realizado e o prazo de pagamento da dívida já tiver vencido e não pago antes da formalização e publicação do contrato de trespasse, o prazo de um ano de solidariedade passiva do alienante (trespasante) será contado da publicação.

Já no caso de um negócio jurídico ser realizado pelo alienante, em que a dívida apenas vier a vencer após dois meses da publicação do contrato de trespasse (dívida vincenda), somente depois de transcorridos esses meses é que começará a fluir o prazo de um ano. Após esse um ano, cessará a solidariedade passiva¹ do alienante relativa a essa dívida e a responsabilidade passará a ser exclusiva do adquirente.



André Ramos (2014, p. 104) chama a atenção para o fato de que essa sistemática de sucessão obrigacional prevista no art. 1146 CC/02 somente se aplica às dívidas negociais do empresário, decorrentes das suas relações travadas em consequência do exercício da empresa (como dívidas com fornecedores ou financiamentos bancários). De outro giro, em se tratando de dívidas tributárias ou de dívidas trabalhistas, não se aplica o disposto referido dispositivo legal, uma vez que a sucessão tributária e a sucessão trabalhista possuem regimes jurídicos próprios, previstos em legislação específica (art. 133 do CTN e 448 da CLT, respectivamente).

Importa destacar também que a nova legislação falimentar (lei 11.101/2005) determina que **a alienação de estabelecimento empresarial realizada em processo de falência ou de recuperação judicial** não acarreta para o adquirente do estabelecimento

¹ Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2005, p. 136), solidariedade passiva “consiste na concorrência de dois ou mais devedores, cada um com dever de prestar a dívida toda”. Assim, o credor pode exigir o pagamento da dívida toda por qualquer um de seus devedores solidários (alienante ou adquirente do estabelecimento) no prazo de um ano, depois disso, só poderá exigir do adquirente.



nenhum ônus, isto é, o adquirente não responderá pelas dívidas anteriores do alienante, inclusive dívidas tributárias e trabalhistas (RAMOS, 2014, p. 104).

Na falência, o assunto está disciplinado no art. 141, II, da referida lei:

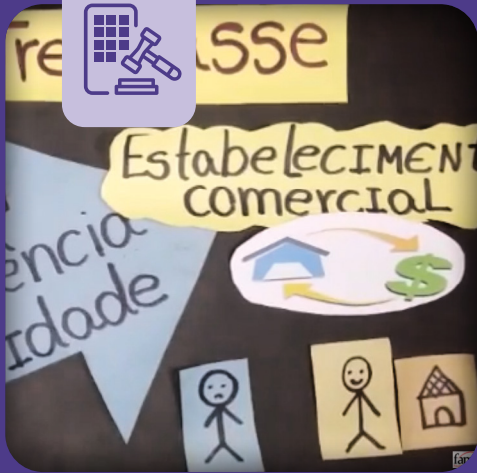
Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo: (...) II - o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.

Já na recuperação judicial, o assunto está disciplinado no art. 60, parágrafo único: “O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei”.

A lei 11.101/2005 trouxe essa disposição normativa com o intuito de tornar mais atrativa a aquisição de estabelecimentos empresariais de empresários em processo de falência ou de recuperação judicial, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

Agora, assista ao seguinte vídeo para recapitular o conteúdo até aqui discutido:

 **VÍDEO**



Tempo: 02 min

Trespasse
Canal: Famig

>>> CLIQUE NESSA IMAGEM E ASSISTA AO VÍDEO <<<

<https://www.youtube.com/watch?v=RaV0OEE-EH8>



b) Proibição de Concorrência:

Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência.

Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato.

Não será possível que o trespassante se reestabeleça para fazer concorrência com o trespassatário dentro do prazo de 5 anos, salvo exista uma cláusula no contrato de trespasse admitindo essa conduta. Precisase ter em mente se há ou não a interferência do potencial econômico de uma atividade na outra. Havendo, aplicar-se-á a vedação legal.

Essa obrigação imposta ao trespassante (alienante) revela-se uma decorrência lógica da aplicação do princípio da boa-fé objetiva às relações contratuais e encontra respaldo em diversos ordenamentos jurídicos estrangeiros. Por óbvio, o trespassatário (adquirente) almeja a clientela do trespassante, razão pela qual o restabelecimento deste, na medida em que pode, claramente, desviar essa clientela, que tende a segui-lo, configura ofensa ao referido princípio, no âmbito do qual se inclui a legítima expectativa do adquirente de 'herdar' a clientela atrelada ao estabelecimento empresarial por ele adquirido (RAMOS, 2014, p. 106).

Obs.: Não se deve interpretar a norma decorrente do art. 1147 do CC/02 de forma a significar que o alienante do estabelecimento não pode se restabelecer. Na verdade, o que o dispositivo legal busca é coibir a concorrência desleal, caracterizada pelo desvio de clientela.

Dessa maneira, não havendo esse desvio, não incidirá a proibição.

CASO PRÁTICO: João possui uma renomada pizzaria há 10 anos e resolve vender seu estabelecimento empresarial. Maria fica interessada começa a pechinchar, mas João não reduz o valor. Maria resolve aceitar e eles celebram o contrato de trespasse. Um ano depois, João resolve exercer novamente uma empresa cujo objeto permeia mais uma vez a gastronomia.

Contudo, o estabelecimento de João está a 200 metros daquele que vendeu a Maria. João poderia ter feito isso? **R:** Não, tendo em vista a proximidade de localização dos estabelecimentos e a semelhança no objeto da empresa, João estaria fazendo concorrência em face de Maria, o que é expressamente vedado pelo art. 1147 CC/02.

Cabe pontuar, conforme o parágrafo único do art 1147 CC/02, no caso do arrendamento ou usufruto do estabelecimento, o prazo da vedação de concorrência do arrendador ou de quem determina o usufruto será o do contrato, na falta da ressalva que permita a concorrência.



Qual a sanção para quem desobedece a vedação de concorrência após a realização do trespasse?

R: Pode ser submetido à apreciação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), o qual determinará as providências cabíveis (venda de ativos, distrato, perdas e danos para terceiros, etc), conforme Art 54 lei 8884/94. Pode também o adquirente do estabelecimento buscar judicialmente uma obrigação de não fazer para que o alienante encerre a nova atividade que constituiu e que estiver gerando a concorrência.

Ainda nesse contexto, cabe esclarecer a **súmula 646 do Supremo Tribunal Federal (STF)**: “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”.

Percebam que essa súmula não revoga o que determina o art. 1147 do CC/02. Ela afirma que um ato legislativo que proíba a instalação de estabelecimentos comerciais em um mesmo lugar e de mesmo ramo ofende o princípio da livre concorrência. Ocorre que, no caso de um alienante de um estabelecimento se instalar posteriormente ao lado do adquirente, fazendo-lhe concorrência, essa concorrência revela-se desleal. Assim, dois estabelecimentos podem tratar de um mesmo ramo em uma mesma região, contanto que nenhum deles sejam um antigo trespasante de outro no prazo de 5 anos. **A vedação do art. 1147 não ofende o princípio da livre concorrência.**

Art. 1.148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, **se não tiverem caráter pessoal**, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante.

Estabelecimento, como regra geral, vai sub-rogar-se em todos os contratos estipulados pelo alienante de modo a garantir a continuidade do desenvolvimento da atividade, salvo pacto em contrário, pois as partes têm liberdade para dispor em sentido diverso.

CASO PRÁTICO: A sociedade empresária A, que atua em uma pousada em Fortaleza, resolve alienar o estabelecimento à sociedade empresária B. Será que a sociedade B vai ter que refazer todos os contratos que a sociedade A havia celebrado para o desenvolvimento da atividade daquela pousada. Será que terá que refazer o contrato com a companhia de fornecimento de energia elétrica, a companhia de captação de esgoto, a companhia de prestação de serviços de limpeza, fornecedores de papel toalha, lavanderia, dentre outros serviços? **R:** Não, a sociedade B automaticamente iria sub-rogar-se nesses contratos que a A havia celebrado, garantindo assim a continuidade da atividade, nos termos do art. 1148 CC/02.



Esta seria a hipótese, por exemplo, dos contratos de arrendamento de gôndolas, de equipamentos ou de aluguel de espaço para fixação de publicidade em um supermercado ou em uma concessionária de carros. Os locadores de tais elementos podem não ter interesse em se vincular ao novo titular do estabelecimento e por isso terão tempo (90 dias) para rescindir esses contratos.

Obs.: É comum acontecer, em caso de débitos com funcionários, que o empregador modifique o seu CNPJ (se for empresário individual) ou o CNPJ da sociedade ou da EIRELI para tentar fugir da dívida, alegando não fazer mais parte da relação obrigacional. Em caso de sociedade ou de EIRELI, haverá desconconsideração da Personalidade jurídica, podendo os credores exigirem os bens pessoais dos sócios que praticaram esse abuso, de maneira ilimitada, isto é, até solver completamente a dívida, e não no limite de suas quotas. Já em caso de Empresário Individual, não há diferença, pois, a responsabilidade já é ilimitada.

Exceção da sub-rogação automática:

Os contratos personalíssimos não são sub-rogados automaticamente ao novo adquirente do estabelecimento. Entendese contrato personalíssimo como aqueles em razão da pessoa (intuitu persona), isto é, um contrato de confiança. Utilizando ainda o exemplo da pousada, imagine que a sociedade A havia celebrado contrato com advogado que se responsabilizava pelas demandas trabalhistas dos ex empregados da pousada. O fato da sociedade B adquirir o estabelecimento da sociedade A não implica a sub-rogação automática desse contrato personalíssimo celebrado entre A e o advogado.



DÚVIDA

Supondo que a atividade que o empresário X desenvolve é realizada em um imóvel alugado, se esse empresário X trespassar o estabelecimento para o empresário Y, será que o adquirente poderá sub-rogar-se desse contrato de locação?

R: Sim, apesar de ser um tema polêmico, a doutrina majoritária e a jurisprudência entendem que o contrato de locação não é personalíssimo.

Na I Jornada de Direito Comercial do CJP, foi aprovado o Enunciado 8, com o seguinte teor: “A sub-rogação do adquirente nos contratos de exploração atinentes ao estabelecimento adquirido desde que não possuam caráter pessoal, é a regra geral, **incluindo o contrato de locação**”.

Embora André Ramos (2014, p. 114) seja contrário a esse entendimento, a doutrina majoritária defende que apesar de ser consensual, o contrato de locação, NÃO é personalíssimo (intuitu personae) nem para o locador e nem para o locatário, vez que o mesmo admite a cessão e a sublocação, não se extinguindo assim pela morte de qualquer deles.



Corroborando esse pensamento, segue o entendimento jurisprudencial:

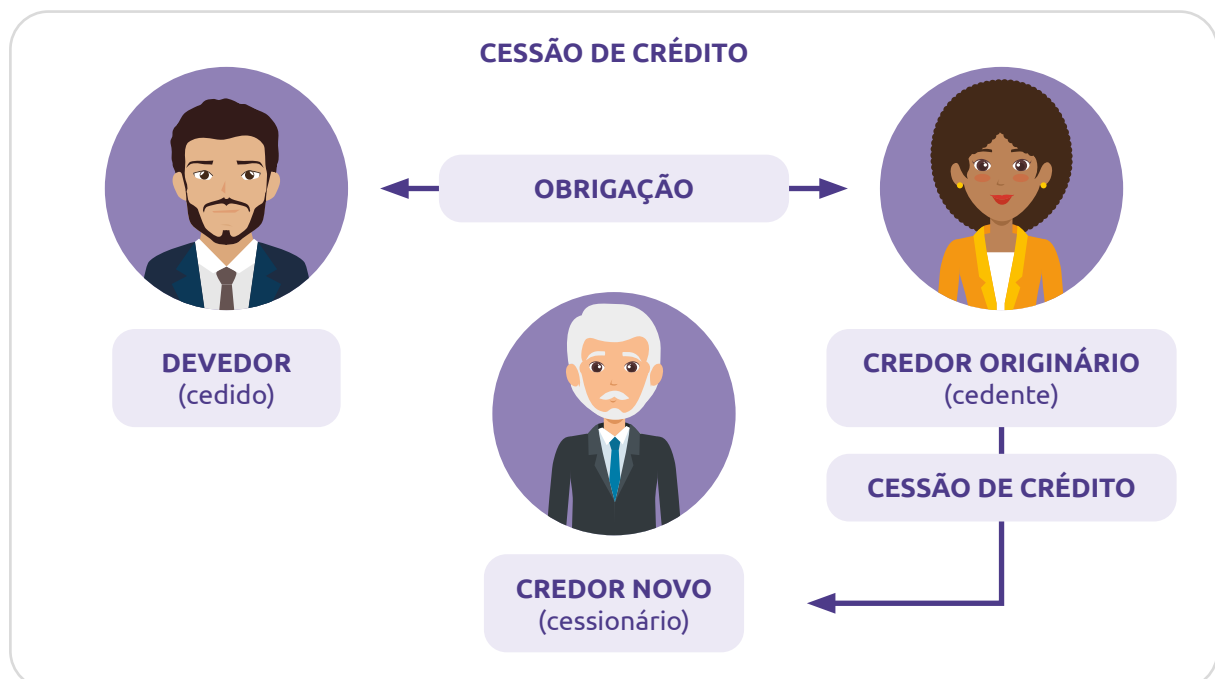
APELAÇÃO CÍVEL DA SENTENÇA EM RECONVENÇÃO – CONTRATO DE ALUGUEL – DIREITO DO HERDEIRO – DIREITOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA EXCESSIVA – RECURSOS IMPROVIDOS – DA PRIMEIRA APELAÇÃO DA BAIMEX E OUTROS: (...)

3. Ademais, por todos é sabido que o **contrato de locação não é personalíssimo**, o que resulta na perfeita possibilidade de que, ocorrendo o falecimento de uma de suas partes, os direitos e deveres contidos nos referidos contratos transferem-se aos herdeiros. (...). Processo: AC24050027218 ES 024050027218; pub10/07/2009.

Todavia, nada impede que, no contrato de locação, fique convencionado entre as partes sobre a impossibilidade de cessão e sublocação, hipótese em que restaria configurado o caráter personalíssimo.

Art. 1.149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente.

Por meio da cessão de crédito, o credor transfere a outra pessoa, no todo ou em parte, a sua posição na relação obrigacional (relação entre credor e devedor). Aquele que realiza a cessão a outrem é denominado cedente. Já a pessoa que recebe o direito de credor é o cessionário, enquanto o devedor é nomeado de cedido. Vale ressaltar que a cessão independe da anuência do devedor (cedido), não precisando consentir com a transmissão. (TARTUCE, 2016, p.441).



A cessão de créditos, ou seja, o repasse dos ativos, em decorrência da transferência do estabelecimento produzirá efeito em relação aos respectivos devedores após a publicação do contrato de trespasse, no sentido de o devedor ter que pagar ao cessionário (adquirente do estabelecimento). Isso porque, com a publicação, o devedor saberia necessariamente da cessão e, portanto, teria de pagar ao credor certo, ou seja, ao novo credor. Contudo, sob o fulcro do princípio da boa-fé, mesmo depois da publicação, o devedor ficará exonerado da dívida quanto ao cessionário se, de boa-fé, pagar ao cedente. Nessa hipótese, caberá ao cessionário promover a cobrança do cedente.



ATENÇÃO

CUIDADO:

Não confunda condições de eficácia com efeitos do contrato de trespasse!

Atributos do Estabelecimento:

Os atributos do estabelecimento são qualidades deste, e não seus elementos. São atributos do estabelecimento a clientela e o aviamento. **Clientela.**

Clientela equivale ao conjunto de pessoas que mantém com o estabelecimento comercial relações contínuas para a aquisição de bens ou de serviços. A expressão clientela foi tomada aos romanos, que assim denominavam os indivíduos que, não pertencendo à família, a ela se agregavam sob a proteção do patriarca. Por vezes, é vista como sinônimo de freguesia, embora tecnicamente as expressões possuam significados distintos, conforme esclarece o professor Oscar Barreto Filho (Apud REQUIÃO, 2014, p. 431-432):

Possui o termo freguesia acentuada conotação de lugar, donde a vantagem de empregá-lo para exprimir a ideia de conjunto de pessoas ligadas a certo estabelecimento, em vista de sua localização ou outros fatores objetivos, reservando-se o termo clientela para o conjunto de pessoas relacionadas com as qualidades subjetivas do titular da casa comercial.

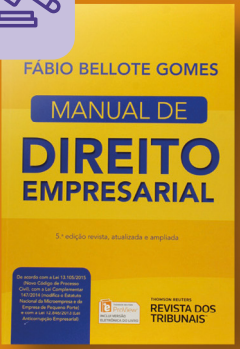
Pode-se afirmar que o freguês consiste em um cliente em potencial. Cite-se como exemplo de cliente uma mulher que sempre corta os cabelos em um determinado salão de beleza. Ela não vai ao salão por acaso, ou porque passou por perto e coincidentemente estava precisando de um corte de cabelo. Essa mulher frequenta o referido salão por confiar na qualidade de seus serviços, mantendo uma relação de 'fidelidade' com o estabelecimento. Por outro lado, um exemplo de freguês seria uma pessoa que mora perto de uma lanchonete, logo é provável que consuma algumas vezes nesse estabelecimento, mas não há uma continuidade frequente.

Aviamento

Antes de iniciarmos a explicação desse atributo, vamos conferir uma pequena introdução feita pelo doutrinador Fábio Bellote Gomes:



 **VÍDEO**

Tempo: 01 min



**Lição de Direito:
AVIAMENTO**

Canal: Professor Bellote

>>> CLIQUE NESSA IMAGEM E ASSISTA AO VÍDEO <<<

<https://www.youtube.com/watch?v=v3nNnFDDlqg>

Considera-se, portanto, o aviamento como aptidão do estabelecimento de gerar lucro ao exercente da empresa, detendo um valor organizacional. Partindo do pressuposto de que a empresa institui uma atividade organizada contendo vários elementos, ou melhor, contendo o estabelecimento comercial vários bens, Rubens Requião (2014, p. 430) afirma que “[...] o valor decorrente desse complexo é maior do que a soma dos elementos isolados. Essa mais valia constitui, precisamente, o que o direito denomina aviamento” (grifo original).

Resulta, portanto, da organização dos elementos e fatores da empresa, influenciando decisivamente no valor do estabelecimento de um empresário. Não entenderam ainda? Vamos para a prática: vocês já notaram que quando a gente chega em um supermercado, aqueles artigos que têm um apelo maior para o público infantil ficam sempre nas prateleiras mais baixas? Isso acontece exatamente com o intuito de que o produto esteja ao alcance das crianças, para que elas insistam com os pais para levar o produto, eles acabam comprando. Existe uma razão de ser, uma lógica, uma intenção por trás da localização daqueles determinados produtos. Essa organização lógica é o aviamento.

Outro exemplo foi o caso da Sociedade Anônima Lotus Development Corporation, que atuava no seguimento da tecnologia, informática, tendo como valor contábil a quantia de 200 milhões de dólares. O valor contábil é o decorrente da do balanço entre o ativo e o passivo da sociedade, em que são avaliados cada um dos bens que compunham o patrimônio da Lótus. Somando ao final todos os valores de cada bem individualmente considerado, chega-se ao valor contábil da Lotus, qual seja 200 milhões de dólares.



Acontece que a sociedade anônima IBM (International Business Machine Corp) adquiriu a Lotus pelo valor de 3 bilhões de dólares, acima do valor contábil, porque a IBM não comprou os bens isoladamente da Lotus, comprou o todo, tudo montado, organizado, a partir de uma lógica, a partir de uma intenção produtiva, de modo que podemos dizer que a diferença entre os 200 milhões de dólares e os 3 bilhões corresponde ao valor organizacional, ou seja, ao aviamento (ROCHA, 1995, online).



QUESTÕES COMENTADAS

✓ QUESTÃO 01

- () A partir de sua instituição, o contrato de trespasse produzirá efeitos quanto a terceiros.

Falso.

O contrato de trespasse precisa observar os requisitos dos art. 1144 e 1145 CC/02 para produzir efeitos perante terceiros (averbação à margem da inscrição do empresário no RPEM e publicação em imprensa oficial).

✓ QUESTÃO 02

- () Caso não haja, no contrato, a cláusula de não concorrência, o alienante poderá fazer concorrência ao adquirente a partir da data da alienação.

Falso.

Conforme art. 1.147 CC/02, o alienante não poderá fazer concorrência ao adquirente pelo prazo de 5 anos, independentemente de cláusula de vedação de concorrência. A clientela, enquanto atributo de estabelecimento, é levada em consideração na estipulação do valor pago no contrato de trespasse. Assim, o adquirente, de certa forma, pagou pelo direito de usufruir daquela clientela. Caso o alienante não respeite a regra, pode o adquirente do estabelecimento buscar judicialmente uma obrigação de não fazer para que o alienante encerre a nova atividade que constituiu e que estiver gerando a concorrência.

✓ QUESTÃO 03

- () A responsabilidade pelo pagamento dos débitos contabilizados anteriormente à alienação caberá ao adquirente do estabelecimento empresarial.

Correto.

Aquele que adquire um estabelecimento empresarial do outro irá assumir os débitos que estiverem devidamente contabilizados, nos termos do art. 1.146 CC/02. Pode-se dizer que a dívida seguirá o estabelecimento.



✓ **QUESTÃO 04**

- () Após a alienação do estabelecimento, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos a vencer existentes no momento do trespasse caberá apenas ao adquirente.

Falso.

Conforme art. 1146 CC/02, o alienante (devedor primitivo) continua solidariamente obrigado pelo prazo de um ano a partir da publicação quanto aos créditos vencidos, ou a partir da data do vencimento quanto aos outros que ainda não venceram no momento da publicação do contrato.

✓ **QUESTÃO 05**

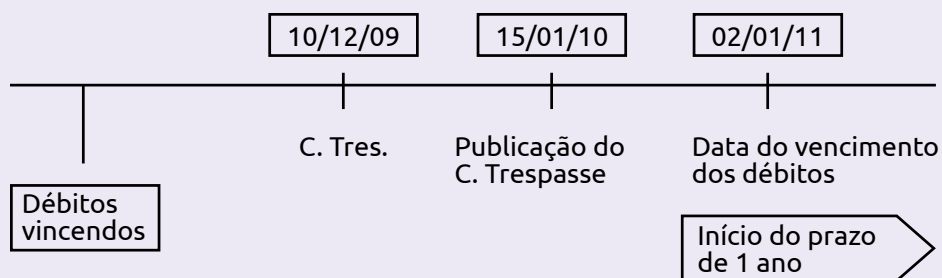
- () Ainda que o empresário tenha, em seu patrimônio, bens suficientes para solver o passivo, a anuência dos credores é pressuposto de eficácia da alienação do estabelecimento.

Falso.

Na verdade, a anuência somente é necessária se o alienante não tiver bens suficientes para solver as dívidas, conforme art. 1.145 CC/02.

✓ **QUESTÃO 06**

- () Após análise minuciosa, Ponto X da moda Ltda. adquiriu, em 10/12/2009, o estabelecimento empresarial da sociedade Alvo Y da Renda Ltda., cujo contrato foi averbado à margem da inscrição da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e publicado na imprensa oficial em 15/1/2010. O referido estabelecimento, quando de sua alienação, apresentava inúmeros débitos regularmente contabilizados, todos com vencimento no dia 2/1/2011. Nessa situação, Ponto X da moda Ltda. continuará solidariamente obrigada ao pagamento dos aludidos débitos até 2/1/2012



Resp.: De acordo com art. 1.146 CC/02, se o contrato de trespasse estiver devidamente regularizado, os débitos serão assumidos pelo adquirente, mas o alienante permanece solidariamente responsável por até um ano após o vencimento da dívida já que ela ocorreu após a publicação. Se o vencimento tivesse ocorrido antes da publicação, o prazo de um ano contaria desta data.

✓ QUESTÃO 07

- () Caso o empresário individual se separe de seu cônjuge, o estabelecimento será considerado pelo valor do somatório do preço dos bens que o compõem, para fins de divisão do patrimônio do casal.

Falso.

Quando se fala em valoração do estabelecimento empresarial, ter-se-á em vista a ideia da Teoria do Aviamento, em que o complexo de bens é visto sob o seu elemento dinâmico, e não estático. Assim, o estabelecimento não será valorado pelo simples somatório dos bens, mas por tudo que sua organização representa, levando-se em consideração o ponto, a posição de mercado, etc. Em um processo de separação, o cônjuge que tem direito à meação do estabelecimento, terá direito que sua avaliação seja realizada pelo seu aspecto dinâmico.





REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 23 mar. 2015.

BRASIL. **Lei 11.101**, de 9 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm>. Acesso em: 11 fev. 2016.

BRASIL. **Lei 10.406**, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm Acesso em: 10 fev. 2016.

BRASIL. **Decreto lei n. 2.848**, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 12 fev. 2016.

BRASIL. **Lei 5.869**, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm>. Acesso em: 12 fev. 2016.

BRASIL. **Lei. 8.934**, de 18 de novembro de 1994. Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8934.htm Acesso em: 11 fev. 2016.

BRASIL. **Decreto n. 737**. Determina a ordem do Juízo no Processo Comercial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DIM737.htm> Acesso em: 11 fev. 2016.

A CIDADE MEDIEVAL. Disponível em: <http://cidademedieval.blogspot.com.br/2011/05/dois-fatores-geradores-da-vida-urbana-o.html>>. Acesso em: 11 fev. 2016

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de direito comercial**: direito de empresa. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial** esquematizado. 4. ed. São Paulo: Método, 2014.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. Vol. 1. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.





ANOTAÇÕES





 /unifametro  @unifametro  unifametro.edu.br